

fluencias de instituciones foráneas; (C) por la atenuación del carácter privado, al pasar muchos juristas a integrar los grandes cuadros burocráticos del Imperio, y del carácter gratuito, al percibirse honorarios y sueldos por la actividad abogadil, docente y administrativa; (D) a pesar de todo, por su libertad frente a los intentos del poder por controlarla y dirigirla; (E) por haberse concretado en una amplísima producción escrita.

LA PRODUCCION ESCRITA

(A) Comentarios sobre el *ius civile*, el edicto, el *ius publicum* —*leges y senatus consulta*— y obras de jurisprudentes antiguos.

(B) Colecciones de *responsa* (respuestas) sobre casos reales o imaginarios.

(C) Obras monográficas sobre típicas o específicas instituciones.

(D) Obras didácticas consistentes en manuales sistematizados o crestomatías de reglas y definiciones.

- Hasta el siglo III d.C., sólo se utilizaba el rollo de papiro (*liber*) que se llamaba *volumen* —proveniente de *volvere* (envolver, enrollar)—. El contenido de un *volumen* o *liber* equivalía a unas cuarenta páginas similares a las que se están leyendo.
- Luego empezó a usarse el pergamino, de mayor duración, en forma plegada y armada —como los actuales libros—, que se designó genéricamente *codex* y en plural *codices*, de donde viene nuestra palabra *código*, cuyo significado específico se originó en que las primeras recopilaciones de *leges* se editaron en esa forma.

IUS PUBLICE RESPONDENDI

Augusto, ya con el propósito de incrementar el prestigio de los grandes juristas, ya con el de atraerlos a su política cultural, dispone el otorgamiento de un verdadero privilegio, el *ius publice respondendi ex auctoritate Principis* (derecho de dar respuestas con carácter público, apoyándose en la *auctoritas* * del Príncipe).

Esta distinción personal —que, por cierto, no impidió que los no agraciados siguieran dando *responsa*— no se sabe si valía para todas las respuestas que pudiera dar su beneficiario, o

si significaba para éste un derecho de someter cada respuesta al Príncipe para su específica aprobación.

Está controvertido también si las *responsa* tenían un valor absoluto obligatorio para los tribunales o sólo una gravitación enriquecida, subrayada, por la *auctoritas* * del Príncipe.

De todos modos, con posterioridad, Adriano, ante la frecuencia de disparidad de criterios entre los juristas, dispuso que fuera obligatoria la doctrina coincidente de los titulares del *ius respondendi*; pero, en el supuesto de divergencias, dejó al tribunal en libertad de elección.

SABINIANOS Y PROCULEYANOS

La rivalidad entre los juristas Capítón y Labeón dio lugar a que se formaran dos círculos o escuelas encabezadas por sus respectivos discípulos, Sabino y Próculo.

Fuera de una evidente modalidad más cautelosa y metódica de los sabinianos, y más imaginativa e innovadora en los proculeyanos, han sido infructuosos y contradictorios los intentos por referir sus divergencias doctrinarias sobre puntos específicos a teorías, sistemas, tendencias o escuelas jurídicas, filosóficas, políticas, etcétera.

PERIODOS DE LA JURISPRUDENCIA CLASICA

(A) De Augusto a Adriano (27 a.C. a 117 d.C.). Caracterizado por el comienzo de la política oficial de gravitación sobre la actividad, hasta entonces privada, de los juristas y por el desarrollo de las dos escuelas de sabinianos y proculeyanos.

(B) De Adriano hasta el fin de los Severos (117 d.C. - 235 d.C.). Iniciado con el gran Salvio Juliano, se distingue por el ingreso de los juristas al *consilium* imperial y a los grandes servicios burocráticos. Los más excelsos juristas romanos son de este período: el popularísimo Gayo, Ulpio Marcelo, Florentino, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Aelio Marciano, Modestino, etcétera.

(C) Del fin de los Severos hasta Diocleciano (235 d.C.-284 d.C.). Signado por la crisis general de la cultura: los juristas,

en funciones administrativas o docentes, trabajan, sin originalidad, en la exégesis y comentario de obras de los otros periodos.

LA LEGISLACION

LEGES PUBLICAE

Luego de una importante producción legislativa promovida por Augusto a través de los comicios tribados y *concilia plebis*, esa fuente de derecho se agotó prácticamente en el primer medio siglo del Principado.

SENADOCONSULTOS

La transferencia de atribuciones que tuvo lugar en el Principado en favor del Senado y en detrimento de los otros órganos de la formalmente subsistente *res publica* se da también en la producción normativa; los magistrados y, cada vez más, el Príncipe, provocaron senadoconsultos innovadores del derecho privado. La asimilación de éstos a las *leges* se acentuó, tanto por la cesación de la actividad comicial, como por la creciente influencia del Príncipe, cuyas iniciativas —*orationes Principis*— empezaron a ser aceptadas por los senadores sin discusión ni votación.

CONSTITUCIONES IMPERIALES

La cesación de la actividad comicial y la pasividad del senado ante las *orationes Principis* abren camino a la creación normativa proveniente directamente del autócrata: "Lo que ha parecido bien al Príncipe tiene fuerza de ley", decía Ulpiano.

De lo constituido por el Príncipe hay que distinguir los *rescripta* y *decreta* —cuyo valor, en un principio, era solamente referido a los casos específicos que los habían provocado— de los *edicta* y *mandata*, que eran disposiciones de aplicación general.

- *Rescriptum* es la respuesta que consigna el Príncipe en el documento con que algún particular o funcionario lo consulta. Se llama *epistula* si se redacta en otro documento.

- *Decretum* es el fallo con que el Príncipe resuelve una controversia que se le ha sometido en única o última instancia.
- *Mandatum* es una pauta o criterio para el ejercicio jurisdiccional *extra ordinem* enviado por el Príncipe a las cabezas de la administración imperial.
- *Edictum* es una norma general para todo el Imperio o parte de él.

LA LABOR JURISDICCIONAL

Pierde su creatividad, tanto por el auge de la normativa promovida por el Príncipe —*leges publicae*, senadoconsultos y constituciones imperiales— como por la extensión del nuevo sistema procesal *extra ordinem*. El edicto va resultando casi puramente translaticio porque poco a poco dejan de incorporarse cláusulas nuevas.

EL EDICTUM PERPETUUM

La culminación y la paralización del *ius honorarium* parece haber sido la codificación que, según versión hoy controvertida, Adriano habría encargado al más grande jurista de la época, Salvio Juliano. A partir de ese *Edictum Perpetuum* ningún magistrado innova: el *ius honorarium* queda cristalizado en ese conjunto de cuarenta y cinco títulos, que si bien no ha llegado hasta nosotros, ha podido ser reconstruido por Lenel, según los comentarios que le dedicaron Salvio Juliano, Gayo, Paulo y Ulpiano.

DERECHO POSCLASICO

CARACTERES

(A) Continuador, sin solución de continuidad, del derecho clásico, aun con la fuerte influencia de las prácticas jurídicas heleno orientales, con la vulgarización resultante de la explosiva extensión de la ciudadanía por obra del edicto de Caracalla del 212 d.C., y con la aceptación del pensamiento cristiano.

- El Derecho Romano, propio de los *civis*, había coexistido con los derechos locales de las comunidades peregrinas y con ese derecho común que fue el *ius gentium*.

- La concesión de la ciudadanía romana a esas comunidades significó que el Derecho Romano iba a ser utilizado por grupos que, no suficientemente romanizados, los desvirtuarían en algunas modalidades típicas por que le introducirían factores extraños a su evolución: resultará, sobre todo en la parte occidental, una normativa de disminuido nivel técnico conocida como *derecho romano vulgar*.
- En la parte oriental el derecho recibirá aportes que darán pie a su calificación como cristiano (Biondi, Riccobono) o helénico (Bonfante, Perozzi).

(B) Deterioro en el nivel técnico o científico, tanto por la aludida irrupción de elementos extraños, como por la decadencia general de la cultura.

(C) Completa fusión de los sistemas de la época preclásica y clásica: *ius civile, ius gentium, ius honorarium, ius novum*...

(D) Desaparición de las tradicionales fuentes del derecho —*leges publicae*, senadoconsultos, interpretación de los juristas, *iurisdictio* del magistrado— y monopolio estatal de la normativa —constituciones imperiales.

(E) Contraposición entre *iura* y *leges*.

- Cualquiera hubiera sido su fuente, todos los criterios o reglas del derecho anterior al posclásico habían sido transmitidos a través de la producción escrita de los juristas: todo ese saber tradicional fue llamado genéricamente *iura* (derecho, normas).
- Las constituciones imperiales, única fuente viva del derecho, se denominaron, también genéricamente, *leges*.

(F) Predominio de un presumido interés social sobre los principios individualistas romanos.

(G) Protección, incluso a expensas de la seguridad jurídica, a la parte considerada débil: la mujer, el pupilo, el deudor, etcétera.

(H) Sustitución de las formas solemnes y de la oralidad por los instrumentos escritos.

LA COSTUMBRE

La subsistencia de prácticas locales en el Imperio Romano, cuando el Derecho Romano se extendió —junto con la ciudadanía (212 d.C.)— a todos los hombres libres, planteó el problema de su valor frente a las normas consagradas autori-

taria o doctrinariamente: frente a la posición de algunos juristas que llegaron a atribuirle a la costumbre un valor derogatorio de la ley, se alzó la voluntad del estado negándosela y admitiéndole sólo un valor supletorio ante el vacío legal, y explicitador de cómo interpreta la comunidad a las instituciones del ordenamiento jurídico.

LA JURISPRUDENCIA

Es anónima y profesional: cargos administrativos, docentes, asistencia en juicios.

Fundamentalmente se dedicó a explicitar, unificar, simplificar y también vulgarizar todo lo tradicional, que será presentado entonces en forma de *iura*.

Se hacen compilaciones A) de *iura*, B) de *leges*, C) de *leges* y de *iura* conjuntamente.

- Entre las *iura*: "Reglas", de Ulpiano; "Sentencias", de Paulo; el "Epítome", de Cayo, de notorio menor nivel que el original, comentario de los comentarios de Ulpiano a Sabino, etcétera.
- Entre las colecciones privadas de *leges* o códigos —como se las llamó por la forma encuadrada en lugar de enrollada—: el "Gregoriano" (292 d.C.), con, por lo menos, catorce libros con constituciones imperiales ordenadas cronológicamente; el "Hermogeniano", a modo de apéndice del anterior, comprendía, fundamentalmente, rescriptos de Diocleciano.
- De las compilaciones privadas de *iura* y *leges* —no se trata aquí de las leyes romano-bárbaras, por su carácter oficial—, las más famosas son los *Fragmenta Vaticana* y la *Collectio legum moscarum et romanarum* (Comparación de leyes romanas y judías).

LEY DE CITAS

Los emperadores, con el fin de asegurar un más claro conocimiento y aplicación judicial del plexo jurídico y de preservar la autenticidad de la doctrina clásica, llegaron a pronunciarse sobre el valor de las obras que en su comentario se realizaban y a reglamentar la invocación de los *iura* ante los tribunales. Así, por ejemplo, una constitución imperial de Constantino del 321 prohibió los comentarios, atribuidos a Paulo y Ulpiano, sobre Papiniano, que habían "depravado" su doctri-

na; otra del 327, en cambio, afirmó la genuinidad de las *Sententiae* de Paulo.

Pero lo que concretó un definitivo dominio del poder político sobre el valor normativo de la doctrina fue la llamada ley de citas de Valentiniano III (año 426). Por ella se dispuso que sólo los *iura* de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino podían citarse ante el tribunal, pero con valor de norma vigente si su doctrina resultaba coincidente en el punto controvertido: no siendo así, predominaba la opinión de la mayoría, para lograr la cual, en caso de empate, se le reconocía un voto suplementario a Papiniano; si de todos modos no se lograba una definición mayoritaria, el tribunal tenía libertad de elegir entre los distintos criterios.

- Teodosio II, emperador en la parte oriental, al ordenar que se insertara en su *Codex* (año 438) aquella constitución de su colega occidental, le añadió una parte en la que se ampliaba la pertinencia de las citas y su valor vinculatorio a los *iura* de los juristas que fueran citados por aquellos cinco, con la condición de que había que ofrecer el cotejo de sus manuscritos.
- Aunque esta condición era de difícil cumplimiento por la escasez y desaparición de los textos, de todos modos, el aditamento teodosiano abrió de nuevo el campo a la invocación, por lo menos en Oriente, de casi todos los juristas clásicos.

LA LEGISLACION

EL CODIGO TEODOSIANO

La gran proliferación de las constituciones imperiales, sus contradicciones, su deficiente publicidad y la falta de una coherente exposición de la doctrina jurisprudencial habían inspirado al nombrado Teodosio II el proyecto de realizar oficialmente una codificación de *leges* y armonizarlas y encuadrarlas con fragmentos selectos de *iura*. Para lograr esto último, Teodosio II alcanzó, sin embargo, a publicar su código de 16 libros, divididos en títulos que comprendían constituciones imperiales ordenadas por su fecha de aparición —del año 313 al 437—. Con el propósito de actualizar lo preceptuado por las *leges* de sus predecesores, Teodosio las hizo todas las supresiones, simpli-

ficaciones, armonizaciones y aditamentos que parecieron necesarios. Las constituciones que no llegaron a figurar en el *Codex* —y que no se encontraban en los "Gregoriano" y "Hermogeniano", oficialmente reconocidos como suplemento de aquél—, quedaban automáticamente sin vigencia.

- El *Codex Theodosianus*, originado en Oriente, fue aceptado en Occidente, donde tuvo mayor importancia y duración.
- En efecto, en Oriente fue suplantado por el de Justiniano.
- En Occidente, en cambio, aun luego de fragmentado aquél en reinos bárbaros, siguió influyendo a través de su recepción en las leyes romano-bárbaras y del cultivo de los estudiosos hasta el llamado renacimiento del Derecho Romano.
- Sólo nos han llegado de él manuscritos parciales y su presencia, sobre todo, en la *lex Romana Visigothorum*.

CORPUS IURIS CIVILIS

Con este nombre —impuesto muchos siglos después, en el año 1583, por el sabio jurista Dionysius Gothofredus—, se designa la compilación y producción jurídica promovida por el emperador Justiniano e integrada por el Código, el Digesto o Pandectas, las Instituciones y las Novelas.

Justiniano quiso un cuerpo actualizado de *leges* y *iura*. Para ello hizo recopilar constituciones imperiales —Código—, fragmentos de los grandes jurisconsultos —Digesto—, redactar un compendio sistemático y didáctico —Instituciones— y promulgó constituciones nuevas —Novelas.

Como el propósito de las compilaciones era el de darles carácter de legislación vigente, Justiniano introdujo en los textos originales de las constituciones de sus predecesores y de los *iura* de los grandes juristas todo tipo de alteraciones, añadidos y supresiones que eliminaran contradicciones y "modernizaran" criterios. Esas modificaciones o desvirtuaciones del texto original constituyen las interpolaciones, cuya detectación o "cacería" ha constituido ardua labor de la romanística moderna.

23

Código. — Una primera edición del año 529 perdió actualidad tanto con la promulgación de cincuenta constituciones que decidieron (*quingenta decisiones*) controversias de la doctrina jurisprudencial, como con la publicación del Digesto. Se dispuso una segunda edición del Código (*Codez repetitae praelectionis*) que, aparecida en el 534, es la única que ha sobrevivido.

- * Está integrado por doce libros divididos en títulos que contienen constituciones ordenadas cronológicamente.

Digesto. — Aparte de ese nombre, que significa en latín ordenamiento, se lo designa también con el vocablo griego *Pandecta* (omnicomprensivo), derivado de *pan* (todo) y *dekhomai* (recibir, abarcar).

- * Encargado en el 530 a una comisión de 16 profesores y abogados presididos por el *quaestor sacri palatii* Triboniano, requirió, según Justiniano, la compulsa de dos mil libros con tres mil renglones.
- * Fue terminado a los tres años, lo que ha promovido teorías explicatorias de tal rapidez: Bluhme (1820) postula la existencia de tres subcomisiones trabajando sobre sendas "masas" o conjuntos de obras; otros autores presuponen, además, tres preexistentes compilaciones de *iura* extractadas de esas masas.
- * Contiene 9.142 fragmentos con 150.000 renglones —individualizados por autor, obra y número del libro de donde fueron extraídos.
- * Es una especie de antología de *iura* de treinta y nueve juristas distinguidos con el *ius respondendi*, excepto, posiblemente, Gayo.

El Digesto aparece dispuesto, según el orden de materias del Edicto Perpetuo, en cincuenta libros, divididos cada uno en dos o más títulos —salvo los libros 30, 31 y 32, agrupados bajo una única rubrica: *de legatis et fideicommissis*.

El contenido, según la división del mismo Justiniano en siete partes, es el siguiente:

Primera parte: principios generales del derecho y la jurisdicción (libros 1 al 4).

Segunda parte: doctrina de la acción y de la protección de derechos reales (libros 5 al 11).

Tercera parte: obligaciones y contratos (libros 12 al 19).

Cuarta parte: obligaciones y relaciones de familia (libros 20 al 27).

Quinta parte: herencias, legados y fideicomisos (libros 28 al 36).

Sexta parte: sucesión pretoriana, aspectos variados de derechos reales, posesión y obligaciones (libros 37 al 44).

Séptima parte: *stipulatio*, derecho penal, apelaciones, derecho municipal, y dos títulos misceláneos: "de la significación de vocablos" y "sobre diversas reglas del antiguo derecho", (libros 45 al 50).

Instituciones. — Sobre la base de la obra del mismo nombre de Gayo, y para suplantarla oficialmente en las escuelas, Triboniano, Teófilo y Doroteo redactaron un manual —que tuvo, además, valor de ley— en cuatro libros: 1) personas; 2) propiedad y sucesión testamentaria; 3) sucesión *ab intestato* y obligaciones generadas por actos lícitos; 4) obligaciones provenientes de actos ilícitos, acciones y derecho penal.

Novelas. — Conjunto de constituciones nuevas (*novellae*), es decir, promulgadas a continuación del Código. No se hizo una colección oficial y se conocen varias privadas, de más de un centenar de constituciones.

INTERPRETACION DEL CORPUS

Su contenido puede ser considerado según dos posturas (*duplex interpretatio*).

(A) Tomado como un ordenamiento vigente, sus tres primeras partes integrantes, el Código, el Digesto y las Instituciones se consideran como un solo cuerpo aunque haya sido promulgados en épocas distintas y así deben interpretarse y armonizarse sus contenidos. Por cierto, es difícil y a veces imposible conciliar las contradicciones, existentes a pesar de la afirmación de Justiniano.

Las Novelas, en cambio, por ser normativa posterior, son derogatorias de cualquier contrario criterio o disposición de las otras tres obras.

(B) Considerado como un material antológico del saber —*iura*— y de la normativa jurídicos —*leges*—, cada uno de los

contenidos del Corpus debe ser analizado en función de la obra de donde fue extractado o de las circunstancias en que la respectiva constitución imperial fue promulgada.

MODO DE CITAR LOS PASAJES DEL CORPUS IURIS

Hay distintos criterios, pero el más practicado en la actualidad es el de ir de mayor a menor, a) indicación de la obra; b) del libro; c) del título; d) del fragmento, de la constitución imperial o del capítulo; e) del párrafo —el primero se marca con pr. que abrevia a *principium*: el segundo resulta entonces 1; el tercero, 2, y así sucesivamente.

Ejemplos:

C. 3, 23, 1 equivale a la constitución primera del título veintitrés del libro tercero del Código.

D. 41, 2, 1, 3 equivale al párrafo cuarto del fragmento primero del título segundo del libro cuadragésimo primero del Digesto.

Inst. 1, 2, pr. equivale al párrafo primero del segundo título del libro primero de las Instituciones.

Nov. 118, 3, 1 equivale al párrafo segundo del capítulo tercero de la novela 118.

CAPITULO IV

VIGENCIA ULTERIOR DEL DERECHO ROMANO

EL DERECHO ROMANO EN ORIENTE

LA PRODUCCION POSJUSTINIANEA

Justiniano, deseando mantener inalterable su producción legal, prohibió que fuera objeto de comentarios e interpretaciones.

Sin embargo, tal disposición fue desoída y proliferaron las traducciones al griego, antologías, comentarios monográficos, etcétera.

LA PARAFRASIS DE TEÓFILO

Entre esas obras se destaca la realizada por uno de los más conspicuos colaboradores en la magna tarea compiladora: la Paráfrasis de Teófilo.

Como su nombre lo indica, es una libérrima explicación en griego del texto latino de las "Instituciones", ampliamente interpretada, comentada y referenciada.

COMPILACIONES BIZANTINAS

La compilación de Justiniano subsistió, naturalmente con transformaciones, a través de compilaciones, adaptaciones, resúmenes, refundiciones, dispuestos por sucesivos emperadores.

- El *Prokheiros nomos* (legislación a mano), compilación de fragmentos ordenada por Basilio el Macedoniano (867-886).
- La *Epagógē ton nomon* (exaltación de las leyes), obra complementaria de la anterior.
- La *Basiliká* (imperial) completa refundición en 60 libros de compilaciones y resúmenes oficiales y privados. Fue ordenada por León el Sabio a fines del siglo IX.
- El *Exabiblos* (seis libros), compilación modernizada de la *Basiliká*, hecha por el juez Armenópulos en 1345, que llega a tener en 1835 fuerza de ley en la flamante Grecia, liberada del poder turco.

EL DERECHO ROMANO EN OCCIDENTE

Aunque en Occidente había terminado, fragmentado en reinos bárbaros, el Imperio Romano, su derecho siguió teniendo, en cierta forma, vigencia (A), en virtud de la concepción de la personalidad * de las leyes, en las legislaciones romano-bárbaras y en las prácticas y costumbres de las poblaciones descendientes de las que habían compuesto el Imperio; (B) por gravitación de los estudios universitarios que fueron consecuencia del llamado Renacimiento del Derecho Romano y (C) por la recepción que de él hicieron los ordenamientos jurídicos de los estados nacionales que se constituyeron en Europa al fin de la Edad Media.

EL SISTEMA DE LA PERSONALIDAD DE LAS LEYES

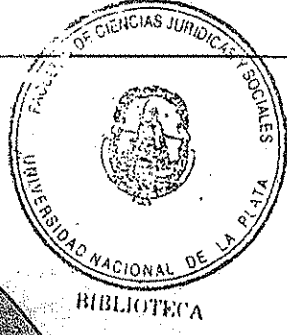
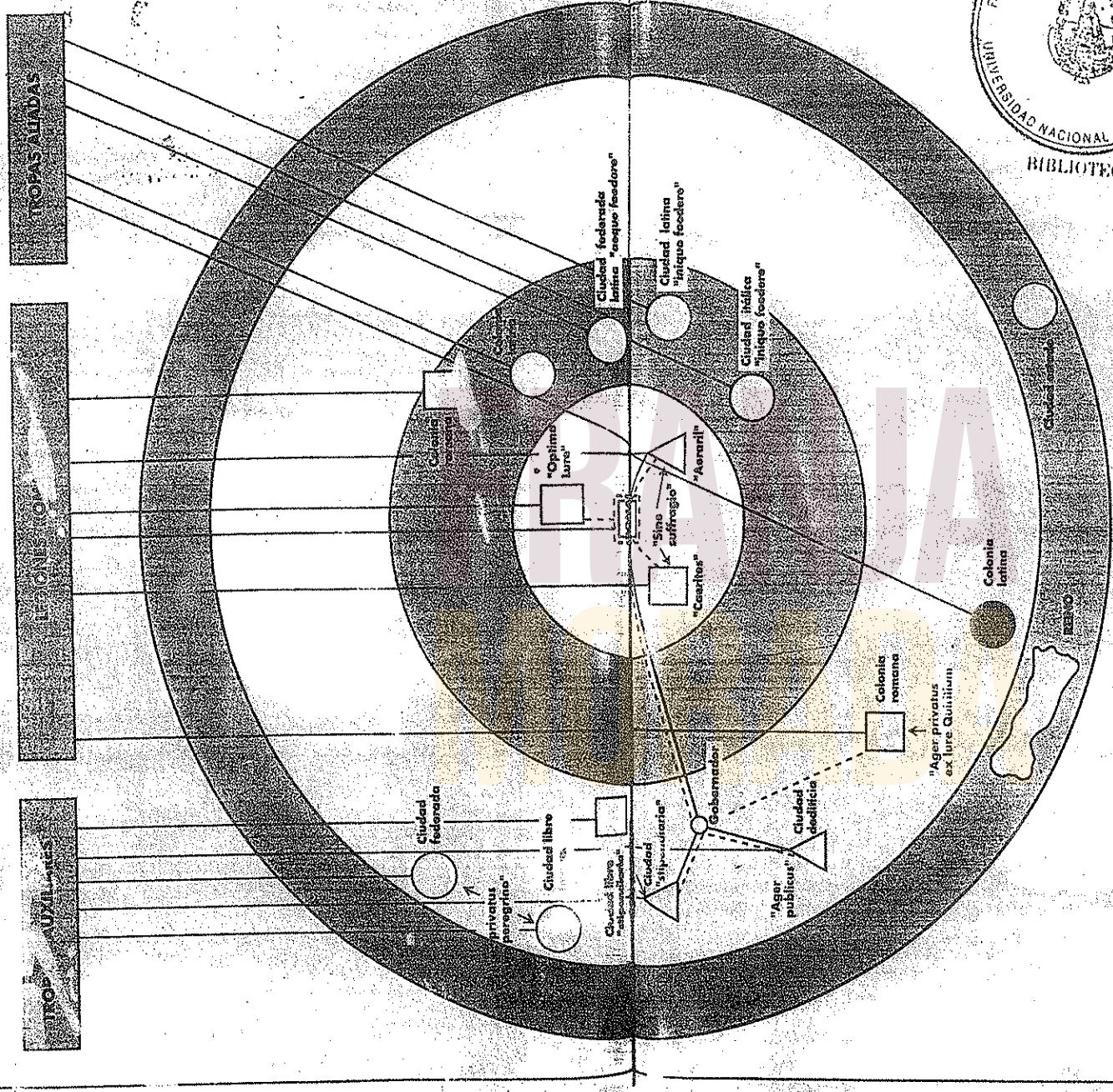
Según sus principios, admitidos unánimemente en el mundo antiguo, las instituciones son exclusivas del grupo étnico y acompañan por doquier sus miembros integrantes.

Ya se vio que el *ius civile* era exclusivo de los *cives* romanos y que se extendió sólo en la medida en que era extendida la ciudadanía. Cuando se establecieron los pueblos bárbaros resultó natural que se manejaran con sus propias leyes y costumbres y que permitieran otro tanto a las poblaciones que habían integrado el Imperio. Los jefes bárbaros mandaron redactar (A) leyes romano-bárbaras, con normativa romana, para el elemento humano romano habitante en sus territorios, (B) leyes bárbaras, consistentes en la redacción de las costumbres de su grupo.

PERIODOS DE LA HISTORIA DE ROMA

Años	CIUDADANIA	ESTRUCTURA DEL AMBITO HEGEMONICO	ORGANIZACION DEL PODER POLITICO	PERIODOS
A.C. 800	Formación de la ciudad			HACIA LA CIUDAD ESTADO
700	Patricios		MONARQUIA	LA CIUDAD QUINTARIA
600				
500				
400	Proceso de acceso de los plebeyos al cuerpo cívico		509: legendaria expulsión del rey	HACIA EL ESTADO NACIONAL
300			367: un cónsul plebeyo. Creación de la pretura	
200	Ciudadanía romana concedida a élites latinas y a latinos anexados	Ciudad estado Roma, única soberana Resto de Italia: zona privilegiada de ciudades aliadas	REPUBLICA	
100	88 A.C. Extensión de la ciudadanía a toda Italia	Resto del imperio: provincias, ciudades aliadas y protectorados	Crisis de la República 27 A.C. Poderes de Augusto	HACIA EL ESTADO UNIVERSAL
D.C. 0	Ciudadanía otorgada parcialmente a habitantes del imperio	Italia = ciudad estado Roma Fuera de Italia: Provincias del Senado Provincias del César Territorios del César	PRINCIPADO	
100			Anarquía militar 284 D.C. Diocleciano	
200	212 D.C. Extensión de la ciudadanía a todo el imperio	Imperio organizado uniformemente en provincias, diócesis, y prefecturas	DOMINADO	HACIA EL ESTADO UNIVERSAL
300			395 división definitiva del imperio en dos partes	
400			565 muerte de Justiniano	
500				DOMINADO
600				

LA REPUBLICA Y SU AMBITO HEGEMONICO



- "Civitas" con soberanía limitada por tratado de alianza, constitución colonial, o "lex data"
- Autonomía administrativa en mayor o menor grado
- △ Sin autonomía administrativa
- Vínculo de sujeción en lo político-administrativo
- Vínculo de sujeción en lo jurisdiccional

- Territorio romano
- Territorio itálico
- Territorio provincial
- Zonas de hegemonía indirecta o protectorados.

- Leyes romano-bárbaras: el Código de Eurico (475), basado en los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano y algunos opúsculos jurisprudenciales; el Edicto de Teodorico (?), redactado en base a los mismos códigos, a las *Sententiae* de Paulo y a las *Institutiones* de Gayo; la *Lex romana visigothorum* (ley romana de los visigodos) o Breviario de Alarico II (485-507), en base a extractos y constituciones de los tres códigos citados, a algunas *sententiae* de Paulo, a un fragmento de los *responsa* de Papiniano y al *Epitome* de Gayo; la *Lex romana burgundionum* (500) del rey Codebando de los burgundios, con las mismas fuentes del Breviario de Alarico.

La fusión de grupos étnicos, la contaminación recíproca de sus normas, el decreciente nivel intelectual de los jueces que fue simplificando las diferencias y alguna legislación común —es decir aplicada territorialmente— fueron, en menos de cuatro siglos, deteriorando el sistema de la personalidad de las leyes.

Ya en el siglo IX la fragmentación feudal y el localismo cultural llevan al principio territorial: en un relativamente pequeño ámbito local un único sistema jurídico aplicable a todos; si hay normas diferenciadas, no se deben a grupos étnicos o nacionales distintos, sino a clases o estamentos sociales.

EL RENACIMIENTO DEL DERECHO ROMANO

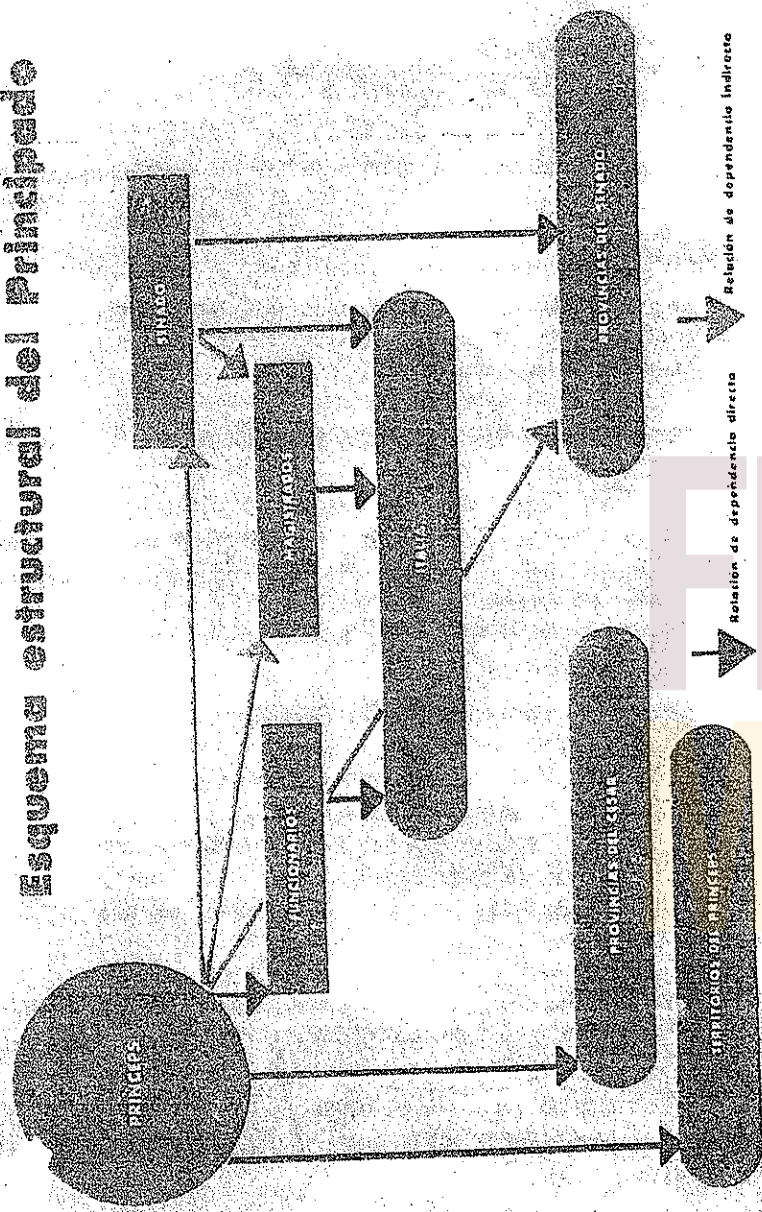
Fue una de las manifestaciones del resurgimiento de la vida urbana en la Europa del siglo XII, después de siglos de aco- samiento, de inseguridades, de estancamiento cultural y de economía agraria de autoabastecimiento.

La aparición de la burguesía, con nuevas inquietudes y posibilidades, se tradujo en la creación y desarrollo de las universidades. Como la sociedad se hacía más compleja y las relaciones entre sus miembros más frecuentes y variadas, se sentía la necesidad de una normativa más discriminadora, más racional, más ecuménica.

En ese clima y en aquel ambiente universitario iba a impactar el “descubrimiento” del precioso legado de la compilación justiniana.



Esquema estructural del Principado



504 1

UNIFICACION DEL REGIMEN MUNICIPAL ROMANO

Antes del 88 a.C.	Entre los años 88 a.C. y 212 a.C.	Consecuencia de la constitución de Caracalla
EN ITALIA Colonias romanas Municipios de ciudadanos "optimo iure" Municipios de ciudadanos "sine suffragio" "Praefecturae" Colonias y "civitates" latinas "Civitates" itálicas	Extensión de la ciudadanía a toda Italia Municipios romanos "optimo iure"	Colonias y municipios con régimen uniformado
FUERA DE ITALIA Municipios romanos Colonias romanas Colonias latinas "Civitates foederatae" y "liberae" "Civitates deditionae"	Municipios con "ius Latii"	

- Es probable que, con anterioridad, las "Instituciones" y el "Código" hayan sido estudiados en Roma, Ravena y Pavía, pero no hay vestigios del "Digesto", la parte de mayor valor científico de toda la compilación.
- A fines del Siglo XI se conoce la existencia de un manuscrito del Digesto escrito a fines del siglo VI, es decir, a medio siglo de su promulgación. Se lo llamó *Littera Pisana* y luego *Littera Florentina*, por haber estado en Pisa y por haber sido llevado en el 1406 a Florencia.
- Irnerio, un profesor de la Facultad de Artes —donde se impartían conocimientos de carácter general y previo a las otras facultades— de Bolonia estudió la *Littera Pisana* y comenzó a interpretarla y enseñarla. Diez mil alumnos de toda Europa concurrieron a Bolonia, interesados en esa forma superior de conocimiento jurídico.
- Pronto, en casi todas las universidades que han ido surgiendo, se encuentran facultades de derecho en las que sólo se estudia el Derecho Romano y el Canónico, formado bajo su influencia y con su mismo carácter de universalidad, frente a los particularismos de los derechos locales, que de ninguna manera se estudian en los claustros.

Según el modo de trabajo y los objetivos buscados, los juristas medievales y renacentistas han sido agrupados en tres escuelas o posturas frente al Derecho Romano: (A) la de los glosadores, (B) la de los comentaristas y (C) la de los humanistas.

La labor de las dos primeras era aludida con la expresión *mos italicus* (manera itálica) —por el predominio de juristas itálicos— y la de los humanistas, *mos gallicus* (manera francesa).

GLOSADORES

Irnerio y sus discípulos realizaron la exégesis de los textos justinianos por medio de glosas, es decir, anotaciones marginales o interlineales, a propósito de una palabra, una institución, un criterio, etcétera.

A mediados del siglo XIII, Accursio, profesor en Bolonia, realizó una ajustada y selectiva compilación de las glosas de sus colegas en forma de un aparato exegético que en las ediciones —manuscritas, por cierto— encuadraba el texto justiniano. Esa *Glossa magna* quedó como definitiva e indiscutida en los claustros y en la práctica judicial.

La postura de los glosadores era de ciega reverencia ante

el texto, al que trataban como una obra perfecta de la razón y no como un producto de diversas épocas históricas, de partes adulteradas por las interpolaciones, de reajustes y adaptaciones no exentos de contradicciones. En eso contrastarían abiertamente con los humanistas. Su gran objetivo era facilitar la comprensión de lo que se les aparecía como un derecho racional de validez general, sin tratarlo promiscuamente con inferiores sistemas locales. En eso se diferenciarían de sus sucesores en el tiempo: los posglosadores o comentaristas.

COMENTARISTAS

Tuvieron una actitud más pragmática: trataron de arrancar del *Corpus Iuris* todo aquel material que, amalgamado con el derecho practicado en ese tiempo y articulado en la concreta realidad contemporánea, pudiera servir para una sociedad en rápido desarrollo. En esa actitud fueron realmente creadores de derecho, de un derecho común europeo de aplicación subsidiaria con respecto a los ordenamientos locales, pero extensible a todo lo no taxativamente dispuesto por éstos.

- Su modalidad de trabajo —a la que deben su denominación— fue la de componer comentarios sobre pasajes de los textos justinianos, con amplio aporte de material jurídico local y canónico.
- El general reconocimiento del valor científico y trascendencia social de la labor de los comentaristas se hace patente en el prestigio de quien puede ser considerado el jurista que más ha gravitado en la formación del derecho occidental: Bartolo de Sassoferrato.

HUMANISTAS

Frente a la actitud reverente y ahistórica de los glosadores y al manipuleo pragmático e integrador de los comentaristas aparecen juristas enrolados en la corriente espiritual del Humanismo, apasionada por el conocimiento integral y circunstanciado del mundo clásico.

Los juristas humanistas veían en el *Corpus Iuris* el resultado de una abigarrada suma y yuxtaposición de elementos que se habían ido dando en el acontecer histórico, con sus contradic-

27 504 1

ciones y vicisitudes, y no una creación atemporal y perfecta de una iluminada razón. Quisieron, pues, entenderlo y explicarlo en la génesis, circunstancias y finalidades de los elementos constituyentes.

- Claro está que esta actitud, que integró importantes vacíos en el conocimiento erudito, sustrajo al Derecho Romano de un contacto y relación con la práctica cotidiana del derecho, como había tenido por obra y gracia de los comentaristas.

LA RECEPCION DEL DERECHO ROMANO

El Derecho Romano había alcanzado nueva vigencia en Europa por la vía de su prestigio y de su cultivo en las universidades. Todos los juristas se formaban en su aprendizaje y, cuando tenían que actuar como consejeros, abogados, jueces o legisladores, aplicaban la letra o el espíritu de ese derecho, único, con el Canónico, que era objeto del estudio universitario.

Así se lo fue recepcionando, en las regiones del centro y occidente europeos, en forma distinta según las circunstancias políticas y culturales.

- En el Sacro Imperio Romano Germánico los emperadores habían aceptado y favorecido el cultivo y aplicación del cuerpo legislativo sancionado por los que ellos querían destacar como predecesores. Más tarde, a partir de 1495, el Tribunal General del Imperio habría de decidir según "el derecho común del Imperio", es decir, el Derecho Romano, impuesto por la vía de los juristas y no por la autoritaria de la legislación.
- En la parte meridional de Francia el Derecho Romano, divulgado por los estudios universitarios, suplió, en su forma escrita, a las costumbres, ya fuertemente romanizadas desde el colapso del Imperio en el 476. En la parte septentrional, las costumbres, muy impregnadas de germanismo, sólo permitieron una aplicación subsidiaria —aunque total en el sistema obligacional— del Derecho Romano.
- En Inglaterra, una monarquía más centralizada había logrado una unificación jurídica a través de un sistema de jueces itinerantes que llevaban a todas partes del reino criterios y prácticas comunes. El "Common Law" resultante hizo innecesario al Derecho Romano, que cumplía un papel similar en las otras regiones europeas. De todos modos, este último campeaba en las universidades —el "Common Law" no se enseñaba en ellas— y formaba la mente y el método de los más destacados juristas.

- En las ciudades libres y principados italianos la rica actividad comercial fue un impulso más a la entusiasta aceptación de la normativa romana como derecho común de cada vez más ciudades, en todo aquello que las normas locales no estatuyeran específicamente.
- En España, el Renacimiento del Derecho Romano produjo una pléyade de profesores formados en Bolonia, que enseñaron en las universidades de Alcalá, Lérida, Valladolid, Valencia y, sobre todo, Salamanca. En las "Siete Partidas" —por la división justiniana del "Digesto"—, de Alfonso el Sabio (1256), se da magnífica puerta a la recepción del Derecho Romano, que aparece allí enciclopédicamente enriquecido con otros elementos, especialmente del Derecho Canónico.

LA TENDENCIA CODIFICADORA Y LA ESCUELA HISTORICA

Por la evolución de los conceptos políticos y jurídicos sobre la organización del estado y, específicamente, por la influencia de la escuela racionalista del derecho natural, tiene lugar, a fines del siglo XVIII, una fuerte tendencia a la formulación de códigos nacionales: el prusiano (1794), francés (1804), austriaco (1811), sajón (1863), italiano (1865), español (1889), para no mencionar los latinoamericanos.

- La redacción de esos códigos cristalizó la presencia del Derecho Romano en la vida europea, pero lo desalojó de la posición —sólo compartida con el Derecho Canónico— que tenía en las universidades: los códigos nacionales serán la columna vertebral de los estudios en las facultades, ahora nacionales y ya no europeas, de derecho.

La llamada Escuela Histórica, liderada por Savigny (1779-1861), considerando que el derecho de un pueblo es producto histórico de la evolución del espíritu nacional, como el arte y la lengua, se opuso a que en el ámbito alemán fuera cristalizado en códigos. Propugnó una vuelta al Derecho Romano como base para una creación doctrinaria, la Pandectística —*Pandecta* era el nombre griego del Digesto—, que fue normativa vigente en Alemania hasta la promulgación del Código Civil Alemán del año 1900.

EL DERECHO ROMANO EN LA ARGENTINA

Su recepción se realizó (A) en forma indirecta e implícita a través de la normativa y doctrina castellana y canónica, (B)



en igual forma a través del espíritu romano que inspiró, en buena medida, las Leyes de Indias, (C) en forma explícita a través del adoctrinamiento dado al clero y de la enseñanza universitaria y (D) a través de la sanción del Código Civil Argentino, justamente considerado como el más rico en contenido jurídico romano.

Según el romanista Díaz Biale se pueden distinguir cuatro períodos en el proceso de recepción.

- Primer período —hasta la fundación de la Universidad de Córdoba en 1814—, con el Derecho Romano implícito en la legislación castellana, canónica y de Indias.
- Segundo período, hasta 1791, en que, al crearse la cátedra de *Instituta* en la Universidad de Córdoba, la enseñanza que allí se había hecho, hasta entonces, del Derecho Romano se hace más directa y orgánica.
- Tercer período, que se cierra en 1834 cuando se publica "Instituciones de Derecho Real de España", de José María Álvarez con notas de Vélez Sársfield.
- Cuarto período, caracterizado por la influencia de aquel libro, que servía de texto en Derecho Civil y en la Cátedra de Derecho Romano de Buenos Aires (1863), por los estudios de Vélez Sársfield y, sobre todo, por la promulgación del Código Civil, redactado por este último romanista.

CAPITULO V

LAS PERSONAS

Con la palabra *persona* se designa hoy al sujeto de derecho, es decir al individuo humano (*persona física*) o ente abstracto (*persona jurídica*) al que el ordenamiento legal reconoce la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones.

- En el Derecho Romano nunca hubo un término técnico para designar al titular de esa capacidad jurídica. Distinguió entre lo que es un *homo* y lo que es una *persona*. Por *homo* se entiende la mera unidad psicofísica, es decir, todo ente que tenga una mente racional en un cuerpo humano. En cambio *persona* es ese mismo hombre, pero considerado "con sus circunstancias", constituidas éstas por la situación que ocupa en la sociedad, en el estado y en la familia; esta situación o "posición jurídica" es conocida con el nombre de *status*. Pero *persona* no fue específicamente empleado en el sentido actual. En realidad, el significado primitivo u original de *persona* era el de máscara utilizada en las representaciones teatrales; por extensión pasó a significar el rol o papel desempeñado por un personaje, y luego la circunstancia, calidad o condición con que se actuaba en sociedad.

Hoy en día, en las naciones civilizadas, sobre la base de la libertad, dignidad e igualdad ante la ley de todos los seres humanos, esa capacidad jurídica es concebida como atributo innato e inseparable de la condición humana. Pero en los pueblos antiguos era atribuida sólo a ciertas personas, según las pautas de sus estructuras políticas y correlativas valoraciones sobre la necesidad o conveniencia de tal atribución. Así, en Roma sólo era reconocida una plena capacidad jurídica en el derecho privado a quien tuviera simultáneamente *status* de li-

28

504 1

bre en la sociedad, *status* de ciudadano en el estado romano y *status* de jefe —*paterfamilias*— en el grupo familiar. Sólo poco a poco —y especialmente después del comienzo de nuestra era— fueron apareciendo o incrementándose restringidas y parciales capacidades de los otros miembros de la familia —mujeres y descendientes—, de la población del Imperio —latinos y peregrinos— y de la sociedad —esclavos.

Es que primitivamente la sociedad civil era considerada como integrada por grupos familiares —*gentes*, familias agnáticas o *proprio iure*— y no individuos: las relaciones jurídicas eran de grupo a grupo, titulariadas precisamente por los respectivos jefes. Sólo con el tiempo, en una sociedad más compleja y articulada y por las necesidades de un mayor desarrollo de relaciones, se fue concediendo mayor autonomía y responsabilidad a los individuos.

Así, pues, en Derecho Romano, a propósito de la persona física, hay que tener en cuenta dos clases de requisitos: 1) los que se refieren a la existencia humana —comienzo y fin— y 2) los que se refieren a su posición —*status*— social, ciudadano y familiar.

Inmediatamente, luego de otros conceptos preliminares, se analizarán esos requisitos, de los cuales en el derecho moderno sólo los primeros tienen relevancia para el reconocimiento de la capacidad jurídica.

Distinta de la capacidad jurídica es la capacidad de hecho o de actuar, que es la aptitud —reconocida al individuo que no se halle afectado por alguna expresa condición disminuyente de sus facultades intelectuales o volitivas— de llevar a cabo actos idóneos para provocar efectos jurídicos.

- Hoy en día cualquier infante o insano declarado puede, en todo momento, adquirir derechos —por ejemplo, resultar heredero—, pero no puede actuar para modificar o extinguir derechos.
- También en Roma ese infante o insano podía —siempre que tuviera el grado óptimo en los tres *status*—, es decir que fuera *paterfamilias* romano— gozar de derechos y adquirirlos, en tanto no fuera necesaria

su personal actuación, invalidada por el ordenamiento jurídico, precisamente en razón del déficit en sus aptitudes intelectuales y volitivas. Era un capaz de derecho pero incapaz de hecho.

- Viceversa, un esclavo, si no presentaba impedimentos de edad o de salud mental, tenía cierta capacidad de actuar; aunque, claro está, los efectos jurídicos de sus actos no recaían sobre él, privado como estaba de capacidad de derecho, sino sobre su dueño. Era capaz de hecho, pero no de derecho.
- En el Derecho Romano, pues, una capacidad no presupone la otra: pueden o no coexistir en un mismo ser humano.

COMIENZO Y FIN DE LA EXISTENCIA

NACIMIENTO

La aparición del hombre en la escena jurídica comienza con el nacimiento. Para considerar nacido a un hombre son necesarias las siguientes condiciones:

(A) La efectividad del nacimiento, es decir, el total desprendimiento del seno materno.

- Mientras el concebido esté en el vientre de la madre se lo considera no como una individualidad, sino sólo como “una parte de la mujer”.
- Sin embargo, por una razón de equidad se le admite un nivel de existencia respecto de ciertos efectos que le son favorables; por ejemplo, donaciones y legados. La afirmación de este principio continuará en Justiniano estableciéndose que siempre que se trate del provecho del concebido, se lo reputa como nacido.
- La evolución posterior de este principio respecto del *nasciturus* (el que va a nacer), al que al parecer no fue ajeno el cristianismo, acuñará más tardíamente la regla *nasciturus pro iam nato habetur* (al *nasciturus* se lo tiene por ya nacido).
- En caso de premuerte del padre —caso del hijo póstumo— el *nasciturus* recibía una protección especial, por medio de un *curator ventris* (procurador del seno materno) designado por el magistrado.

(B) Que haya nacido con vida, pues “a quien na e muerto, no se lo tiene ni por nacido ni por procreado”.

- Hubo acá una controversia entre las escuelas acerca de la prueba de haber nacido con vida. Para los proculeyanos era necesario haber escuchado el grito del recién nacido; en cambio, para los sabinianos bastaba con cualquier signo, fuera el de la voz u otros. Fue por esta tesis por la que se inclinó Justiniano.

(C) Que el nacido presente forma humana, puesto que si la mujer ha dado a luz algo monstruoso o prodigioso, es decir

procreado en contra de la forma normal de la figura humana, ello no tiene ninguna significación jurídica.

MUERTE

La muerte extingue al *homo* y en consecuencia deja éste de ser persona.

- * Se planteaba el problema de determinar el orden de prelación de quienes morían en un mismo accidente —incendio, naufragio, etcétera—. Ello podría tener importancia en el caso del orden sucesorio.
- * Para el derecho clásico, si no se podía probar quien murió antes y quien murió después, se consideraba que "no se veía que uno haya sobrevivido respecto del otro", por lo que ambos eran tenidos como muertos al mismo tiempo.
- * En cambio, Justiniano siguió otro sistema, al establecer una presunción para un caso particular. Se basaba en un criterio de mayor o menor resistencia a la muerte: así, si en el accidente perecen el padre y el hijo, se presume que si el hijo es impúber se lo tiene como muerto antes; en cambio, si es púber, se lo tiene por muerto primero al padre, siempre que no se pruebe lo contrario. Anteriormente Adriano también había decidido en un caso así, que el hijo muere antes que el padre.
- * Los romanos no conocieron las presunciones y declaraciones de muerte. Fueron los glosadores quienes sentaron el criterio de que cabe presumir la muerte del ausente —salvo prueba en contrario— que ha cumplido 100 años. La interpretación medieval posterior, basada en el Salmo 90 (89) v. 10, rebajó el cómputo a 70 años.

EL "STATUS"

El status es la situación o posición jurídica ocupada por un hombre. Se acostumbra a dividir tres clases distintas:

- status libertatis → de acuerdo con la *libertas*
- status civitatis → de acuerdo con la ubicación en la *civitas*
- status familiae → de acuerdo con la ubicación en la *familia*

- * La clasificación precedente no sería típicamente romana, sino elaborada posteriormente (s. XVI y siguientes), tomando como base la idea, que sí era romana, de la *capitis diminutio*. Los romanos establecían tres clases: *capitis diminutio maxima* (cuando alguien perdía la libertad), *capitis diminutio media* (cuando alguien perdía la ciudadanía) y *capitis diminutio minima* (cuando alguien perdía su posición dentro de la familia o cambiaba de familia).

STATUS LIBERTATIS

La máxima división de los hombres (*summa divisio hominum*) es la que nos dice que los hombres son libres o son esclavos. A su vez, los libres son ingenuos o son libertos.

LOS ESCLAVOS

El esclavo es aquel hombre que por una *iusta causa* está privado de su libertad y debe servir a un hombre libre.

- * Florentino nos da una definición de la esclavitud inspirada en el estoicismo, según la cual es "una institución del derecho de gentes, por la cual alguien se encuentra sometido —en contra de la naturaleza— a un dominio ajeno".
- * Para que exista la situación de esclavo es necesario que medie una causa legal de esclavitud; de lo contrario el hombre continúa siendo libre. Se podía dar el caso del hombre que no obstante ser libre, estaba sirviendo de buena fe como esclavo (*homo liber bona fide serviens*). En este caso sus actos se regían por las reglas de la esclavitud.

Respecto de los esclavos nos interesa destacar: (A) cómo se llega a ser esclavo; (B) cuál es la condición jurídica del esclavo; (C) cómo se cesa de ser esclavo.

(A) Cómo se llega a ser esclavo. — Los esclavos *nacen o se hacen*: 1) nacen esclavos los hijos de esclavas. Se hacen esclavos los hombres, 2) por causas del *ius gentium*, 3) por causas del *ius civile*.

- 1) Nacen esclavos los hijos de una madre esclava. Poco importa que el padre sea libre o esclavo, pues fuera del matrimonio legítimo (*iustae nuptiae*), único supuesto en el cual el *pater es certus*, la regla es que el hijo sigue la condición de la madre. Como los esclavos no pueden celebrar *iustae nuptiae*, se explica la solución dada.

- * ¿Cuándo se toma en cuenta la situación de la madre? Podría suceder que fuera libre en la concepción y esclava en el parto de su hijo, o viceversa. Los romanos tuvieron sus dudas, pero luego, por aplica-

29

504 1

ción del principio del *favor libertatis* (en caso de duda estar por la libertad) se estableció que bastaba que la mujer hubiese sido libre, aunque más no hubiese sido un momento, en el embarazo para que el hijo naciera libre.

- 2) Se hacen esclavos por el *ius gentium* los aprehendidos en una guerra de acuerdo a derecho (*iustum bellum*), es decir una guerra formalmente declarada contra aquellos pueblos con los cuales Roma mantiene vínculos regulares (*hostes*), o también una guerra sin declaración formal con aquellos pueblos desconocidos para Roma (*barbari*).
- En principio, los cautivos extranjeros pasan a ser esclavos del *populus romanus*, el cual puede utilizarlos para trabajos públicos, o también subastarlos a los particulares. Raramente eran cedidos a los soldados y jefes.
- Siendo una causa del *ius gentium*, el romano podía también ser aprehendido por el enemigo. En ese supuesto, para el caso de que escapara de su cautiverio y transpusiera los límites de terreno romano, se hacía de cuenta que no sólo recobraba su libertad, sino también su *ingenuitas*; es decir, se lo reintegraba a la misma situación jurídica que gozaba antes de caer prisionero. Esta institución se llamaba *postliminium* (*post*= después de; *limen*= límites).
- Otra ventaja de que contó el romano prisionero era la *factio legis Corneliae*. Un romano podía hacer testamento, pero para que éste fuera válido debía contar con la capacidad activa de hacerlo (*testamenti factio activa*), tanto en el momento de su confección como en el de su muerte. En el caso que nos ocupa, si moría prisionero del enemigo, el testamento se tornaba inválido. Para salvar la validez del acto la *lex Corneliae* estableció la ficción de que al romano muerto en cautiverio se lo considerara muerto en el mismo momento en que había caído prisionero.
- 3) Se hacían esclavos por el *ius civile* —supuestos más raros— por las causas siguientes:
 - los que rehusaban inscribirse en el censo o alistarse para la leva;
 - los condenados a penas infamantes (*servi poenae*), como la de ser obligados a trabajar en las minas, condenados a las bestias feroces, a ejercer de gladiadores, etcétera;
 - la mujer libre que mantenía relaciones ilícitas con un esclavo ajeno no obstante la triple advertencia del *dominus* de dicho esclavo de que las mismas debían cesar.
 - Todas estas causas fueron derogadas posteriormente y en la época de Justiniano quedaron prácticamente sólo dos: a) el caso del hombre libre mayor de 20 años que en convivencia con otro se hace vender por éste a un tercero como esclavo, para luego declarar su verdadero *status* y defraudar al comprador en el precio pagado; b) por ingratitude de un liberto respecto de su patrono.

(B) Condición del esclavo. — En principio, el esclavo no tiene capacidad de derecho; es decir, no puede celebrar por sí

actos jurídicos. Técnicamente es cosa (*res*), y en tal calidad queda sujeto a la propiedad de su amo.

- Sin embargo, creemos que la palabra exacta para designarlo es *homo*, que lo diferencia de una mera *res*.
- Por ello es que, si bien no podía hacer actos jurídicos por sí, tenía capacidad de actuar por su *dominus* en los actos cuyo objeto era hacerle adquirir bienes o convertirlo en acreedor, pero no en aquellos que significaban hacerle perder bienes o convertirlo en deudor: por ejemplo, podía adquirir para su dueño por ocupación, herencia, etcétera, o celebrar una *mancipatio* o una *stipulatio* que beneficiasen a éste.
- También podía retener ciertos bienes en calidad de *peculio*.
- Desde el punto de vista penal era *capax*, de tal modo que su *dominus* respondía por los delitos cometidos por su esclavo, pudiendo optar entre abonar la pena o recurrir al abandono nozal.
- Como *homo* que es, se lo reconoce como sujeto del *ius naturale*: así, no podía contraer *iustas nuptias*, pero sí unirse por el *contubernium*. Como consecuencia de esta unión se admitió un parentesco de sangre (*servilis cognatio*) que tenía repercusión si el esclavo llegaba eventualmente, por una manumisión, a ser liberto en los impedimentos matrimoniales y para los supuestos de herencia. También se admitió que las obligaciones celebradas *per se*, si bien no eran obligaciones civiles, tenían los efectos de las obligaciones naturales.
- Finalmente, en el orden religioso se lo consideraba participe tanto del culto familiar como del público, teniendo validez la palabra empeñada en los juramentos y votos. El sitio donde descansaban sus restos era una *res religiosa*, mereciendo por ello las honras fúnebres.

En cuanto a su situación, el esclavo dependía mucho del trato particular que le dispensaba cada *dominus*. Podemos distinguir varias etapas.

- 1) En un principio, los esclavos eran de la misma condición étnica y aun religiosa de sus amos, por lo que convivían con ellos, trabajando junto a sus hijos y participando del culto. Incluso más adelante, muchos esclavos helénicos estarían encargados como pedagogos de la instrucción de los niños.
- 2) Hacia fines de la República, la situación cambia. El número aumenta, y siendo en su mayoría extranjeros cautivos, se los mantenía alejados de la casa familiar, haciéndolos trabajar en los campos de sus dueños.
- 3) Sin embargo, la rudeza de ciertos amos se fue suavizando por efectos de distintas disposiciones, originadas por una neta influencia estoica, a la que se agregó luego la cristiana.

- * Para el estoicismo, el principio de la *humanitas* hizo mirar con animadversión a la esclavitud. El camino fue sin embargo bastante lento en cuanto a las correcciones.
- * Por la *lex Petronia* (19 d.C.) se prohibió condenar al esclavo a las bestias.
- * Por edicto de Claudio se prohibió al *dominus* abandonar a su esclavo viejo o enfermo, bajo pena de perder el *dominium* del mismo.
- * Antonino Pio dispuso que si alguien mataba al esclavo propio, se lo hacía responsable como si se tratase de la muerte de un esclavo ajeno. Además, le estaba prohibido maltratarlo, bajo pena de ser obligado a venderlo por orden del magistrado.
- * La influencia cristiana se hizo ver a partir de Constantino, quien calificó de homicidio la muerte intencional del esclavo. Ya en la época de Justiniano se redujeron las causas de esclavitud y se proveyeron diversas medidas para evitar actos de crueldad respecto de los esclavos.

(C) Cómo se cesa de ser esclavo. — La situación de esclavitud cesa por voluntad de la ley o por voluntad del amo que manumite (*manus* = poder; *mittere* = enviar, abandonar).

- * Muchas veces la ley podía disponer la libertad de un esclavo; por ejemplo, por haber prestado un servicio importante al *populus* —descubriendo una conspiración, denunciando delitos, etcétera—. También hubo normas más genéricas, como el citado edicto de Claudio, que otorgaba la libertad al esclavo abandonado por su dueño; o la disposición de Constantino por la que el esclavo recién nacido y abandonado era libre.
- * En cambio, dependía de la voluntad del amo el manumitir.

En el derecho clásico había tres clases de manumisiones solemnes:

1) por la vindicta

- * En este caso, el *dominus* concurría con el esclavo delante del magistrado debiendo estar presente un tercero (*adsertor libertatis*) que actuaba por el esclavo, quien no podía actuar en justicia. Este tercero era comúnmente uno de los lictores que acompañaban al magistrado. Afirmaba solemnemente que el esclavo era un hombre libre, y ante el silencio del *dominus*, el pretor lo declaraba como tal.

2) por el censo

- * Consistía en permitir al esclavo inscribirse en el censo en la clase de los ciudadanos. Como es sabido, el censo tenía lugar cada cinco años en Roma.

3) por testamento.

- * El amo podía acordar en su testamento la libertad a su esclavo, ya sea directamente, por una cláusula inserta al mismo, ya indirectamente, por medio de un legado * que debía cumplir el heredero, o también

por medio de un fideicomiso * que debía cumplir el heredero fiduciario.

En el Bajo Imperio, a partir de Constantino se admitió una nueva forma, influida por el cristianismo: la manumisión en la iglesia (*in sacrosanctis ecclesiis*).

- * Se realizaba en las iglesias, en presencia del obispo y de la grey reunida; se utilizaba generalmente el día de Pascua, y luego de la declaración del *dominus*, se redactaba un libelo o escritura, firmado por los presentes, que actuaban de testigos.

Aparte de las formas rituales solemnes, podía suceder que el *dominus* decidiera otorgar la libertad a su esclavo de un modo informal. Así, haciéndolo en presencia de sus amigos (*inter amicos*), o invitándolo a compartir la mesa (*per mensam*), o haciéndoselo saber por una carta (*per epistolam*).

- * Ocurría acá una situación curiosa, por cuanto, de hecho, el esclavo estaba manumitido, aun cuando para el *ius civile*, por no haberse cumplimentado los ritos respectivos, permanecía esclavo. Tanto era así que el *dominus* arrepentido podía reclamar al pretendido manumitido por medio de una *reindicatio*. Sin embargo, acá intervenía el pretor otorgando al demandado una serie de defensas (*exceptiones* *) por las que se detenían los efectos de la acción incoada.
- * Esta situación ambivalente —esclavo para el *ius civile*, libre para el *ius praetorium*— fue finalmente resuelta por la *lex Iunia Norbana*, que declaró que estos libertos serían libres, ubicándolos en el status de *latini iuniani* *.

En un principio, la posibilidad de manumitir fue totalmente libre. Debido al carácter familiar de los esclavos, era, incluso, bastante rara. Luego, en plena República, se consideraba un honor para el *dominus* el manumitir, lo cual representaba un rasgo de generosidad. Sin embargo, como estas manumisiones podían afectar otros intereses, se sancionaron leyes restrictivas de las manumisiones: la *lex Aelia Sentia* y la *Fufia Caninia*.

- * La *lex Aelia Sentia* limitó la posibilidad de manumitir *per vindictam*. Su objetivo estaba relacionado con el hecho de que, siendo la mayor cantidad de esclavos de esa época (año 4 d.C.) extranjeros, por una ligereza de los dueños se otorgara la libertad a individuos que no eran dignos de ser ciudadanos romanos, o pudiera resultar peligroso para la seguridad pública el otorgarles la ciudadanía. Por ello esta ley pedía: a) que el *dominus* tuviera por lo menos 20 años —de lo contrario era nula la manumisión—; b) que el manumitido tuviera por lo menos

30 años —de lo contrario se convertía en *latinus iunianus*—; c) no se podía manumitir a esclavos que fueran tales por penas infamantes. Si no obstante se lo hacía, se convertían en *libertos dediticios**, y d) no se podía manumitir en fraude de los acreedores.

- En cambio, la *lex Fufia Caninia* (año 2 d.C.) limitó el número de esclavos manumitidos por testamento. Su objetivo era que no se perjudicara a los herederos. Se establecía una tabla progresiva, siendo el máximo permitido el de 100.
- Justiniano derogó la *lex Fufia Caninia* y mantuvo la *lex Aelia Sentia* en lo que se refería a la edad del *dominus* para manumitir y en cuanto a la prohibición de manumitir en fraude de los acreedores.

LOS LIBRES

(A) Los ingenuos — Son quienes han nacido libres y lo continúan siendo. En esto se diferenciarán del liberto, quien si bien es libre, antes fue esclavo y luego fue manumitido. Para considerar la ingenuidad no importa si el padre fue ingenuo o liberto.

(B) Los libertos. — En la época clásica se diferencian tres clases de libertos.

1) Los libertos ciudadanos romanos. Eran tales los manumitidos por formas solemnes, habiéndose respetado las normas de la *lex Aelia Sentia*.

- Esta categoría de libertos era la que más se parecía a la de los ingenuos ciudadanos romanos. Sin embargo, había algunas diferencias. En lo que respecta al *ius publicum*, carecían del *ius honorum*, y si bien tenían el *ius suffragii*, sólo les era permitido intervenir en los comicios tribados votando exclusivamente en alguna de las cuatro tribus urbanas. En lo que se refiere al *ius civile*, es decir el *ius commercii**, y también el *ius connubii**. Respecto de esto último, durante mucho tiempo estuvo, sin embargo, prohibida la realización de *Iustae nuptiae** entre ingenuos y libertos. Augusto la permitió, pero sin acordarles a las libertas la posibilidad de casarse con personas del rango senatorial.
- Esta clase de libertos podía conseguir en la época imperial la *ingenuitas*, mediante la concesión del príncipe del *ius aureorum anulorum* (derecho de anillos de oro) de los caballeros, si bien quedaba vigente la relación de patronato*. En cambio, por la *natalium restitutio**, concedida por decreto del príncipe con el consentimiento del patrono, el liberto era igual al ingenuo, y desaparecía el patronato.

2) Los libertos latinos jonianos. Eran éstos quienes a) fueran manumitidos por formas no solemnes; b) o no contaran

con la edad de 30 años; c) o fueran manumitidos por un *dominus* que sólo tenía sobre ellos el dominio bonitario*.

- Esta categoría era inferior a la anterior. En lo que se refiere al *ius publicum*, carecían tanto del *ius honorum* como del *ius suffragii*.
- En lo que se refiere al *ius privatum*, carecían del *ius connubii*, pero poseían el *ius commercii*, por lo que su situación se parecía a la de los latinos colonarios, pero se diferenciaba en cuanto a que esta posibilidad quedaba limitada a los actos *inter vivos*. Respecto de los actos *mortis causa*, no podían ni hacer testamento ni tampoco adquirir nada a título de herederos o de legatarios. Ulpiano resumía su situación diciendo que "viven como libres, pero mueren como esclavos".

- Quienes estaban en esta categoría, en la época clásica podían, por diversos procedimientos, ascender a la de "ciudadanos romanos": Así,

a) si era latino jonio por no contar aún 30 años, si se casaba —no *Iustae nuptiae*— con una mujer ciudadana, romana o latina, y tenían un hijo, cuando éste llegaba al año de edad, se podía presentar al magistrado o al gobernador pidiendo la ciudadanía romana.

b) Todo latino jonio se hacía ciudadano romano si había militado durante 6 años en la guardia de Roma; más tarde, por un senadoconsulto, se rebajó a 3 años.

c) Ello también ocurría si el latino había construido una nave capaz de llevar no menos de diez mil medidas de trigo, y había efectuado el tráfico a Roma llevando trigo durante 6 años.

d) Además, Nerón otorgó la ciudadanía al latino cuyo patrimonio se elevara a más de 200.000 sesteracios y edificara en Roma una casa en la cual invirtiese al menos la mitad de su patrimonio.

e) Por último, Trajano ordenó otorgar la ciudadanía al latino que hubiese ejercido en Roma durante tres años el oficio de molinero, o panadero, y hubiese molido no menos de 100 medidas de trigo diarias.

- Todas estas disposiciones están vinculadas, como es fácil advertir, con distintas necesidades públicas en la vida de Roma.

3) Los libertos dediticios. Eran éstos los esclavos por penas infamantes (*servi poenae*) que hubieran sido manumitidos.

- Según Cayo, era la peor de todas las situaciones en que podía estar un hombre libre (*passima libertas*). En efecto, quedaban asimilados a la categoría de los peregrinos dediticios*. No podían llegar a ser ni latinos ni menos aún ciudadanos romanos.

- A su vez, les estaba prohibido vivir en Roma o en un radio de 100 millas alrededor. Si contravenían esta disposición, tanto a ellos como a sus bienes se los vendía públicamente.

En el Bajo Imperio no hay sino una sola clase de libertos: la de ciudadanos romanos, habiendo desaparecido la de los latinos iunianos y la de los dediticios.

El patronato. — El liberto quedaba ligado a su antiguo amo por medio de un vínculo que arrastraba una serie de deberes a cumplir; el amo, luego de la manumisión, pasaba a ser denominado *patronus*. Esa situación era conocida como patronato. Los deberes eran los siguientes:

(A) El *obsequium*

- * Llamado también *reverentia* u *honor*, consistente en el deber de respeto debido al patrono y a sus descendientes. El liberto no debía realizar ninguna acción infamante ni demandarlo judicialmente sin una autorización del pretor. Si el patrono caía en la miseria, podía reclamarle alimentos al liberto; en este supuesto, la obligación era recíproca y el patrono estaba obligado a sostener al liberto indigente.

(B) Las *operae*

- * Consistían en servicios que debía prestar el liberto. Había dos clases: *operae officiales*, generalmente servicios domésticos a los que estaba acostumbrado el liberto, de un carácter netamente personal y debidos sin necesidad de convención al respecto; pero además podían ser *operae fabriles*, que tenían un carácter más extraordinario, generalmente involucrando un valor pecuniario. Para poder exigirlos era necesario haber mediado una promesa juramentada, que era una forma contractual verbal, la *promissio iurata liberti*.

(C) Los *bona*

- * Cuando el liberto moría sin descendientes habidos luego de su manumisión, los bienes correspondían a su patrono. Este tenía también la tutela del liberto impúber o de la liberta.

Las obligaciones del liberto hacia su patrono pasan a los descendientes de éste, quienes pueden exigir su cumplimiento. En cambio, el que debe cumplirlas es el liberto, y en principio no pasan a sus hijos, quienes nacen ingenuos. Sin embargo, de hecho quedaban bajo la dependencia moral del patrono, luego de la muerte de su padre.

SITUACIONES AFINES A LA ESCLAVITUD

Ciertos hombres, no obstante no ser esclavos, estaban sometidos a una situación muy cercana a la esclavitud. Serían los casos siguientes:

1) Las personas *in mancipio* o *in causa mancipii*

- * Estaban en esta situación los *filifamiliae* que el *pater* transmitía por una *mancipatio* a otro *pater*. Las causas podían ser varias y no

llevaban generalmente la idea del simple lucro. Así, podía efectuarse la *mancipatio* para realizar los requisitos de una emancipación o de una adopción, o para entregar el hijo a la guarda de un tercero con fines de aprendizaje. También, el *pater* podía mancipar a un *filius* a los efectos de no hacerse cargo de la responsabilidad por daños delictivos cometidos por ese *filius*. Este supuesto es conocido como *abandono noxal*.

- * En cuanto a su situación, es muy parecida a la del esclavo; los textos dicen que está *in loco seroi* (ocupando el lugar de esclavo) y sometido al *mancipium* del *pater* adquirente. Se diferencia del esclavo en que continúa teniendo su *status libertatis* y por ello, cuando termine esta situación, continuará siendo ingenuo y no dejará de ser ciudadano romano.
- * Para salir de esta situación era necesaria una manumisión solemne.
- * Para la época de Gayo, la situación de personas *in causa mancipii* ha quedado reducida a los casos de abandono noxal. Ya para Justiniano, el *mancipium* ha desaparecido.

2) Los *colonos*

- * El colonato es una institución tardía de Roma —fines del siglo IV d.C.—. El *colonus* era un hombre libre y como tal podía casarse, tener patrimonio, contraer obligaciones, etcétera; pero se hallaba adscripto, con toda su familia, a la tierra de la que formaba parte, siendo por ello un siervo de la tierra (*seruus terrae*).
- * No podía abandonar la tierra, y si lo hacía, era tratado como un esclavo fugitivo. Además, cuando se vendía la tierra, el colono y los suyos eran vendidos como accesorios de la misma.
- * Para ser colono, la fuente más frecuente era el nacimiento; pero podía ocurrir también por convención, o a título de pena. La extinción era más difícil. Ocurría cuando el colono alcanzaba a comprar el campo o la porción de éste al que estaba sujeto. También cuando el patrono lo ofrecía como soldado, como decurión o como sacerdote. En cambio, si alcanzaba la dignidad de obispo, no era necesario el consentimiento del patrono.

3) Los *addicti* y los *nexi*

- * Los *addicti* son aquellos deudores que no habiendo pagado sus deudas han sufrido los efectos de la *manus iniectio* por parte de sus acreedores. Situación semejante es la de los *nexi*, es decir los deudores que se han obligado por medio del *nexum* y no cumplen la prestación debida.
- * Técnicamente no son esclavos, y en Roma continúan siendo ciudadanos, pero su situación real es muy cercana a la esclavitud: posibilidad de tenerlos presos privadamente durante 60 días, al cabo de los cuales podían ser vendidos o atribuidos en propiedad.

4) El *auctoratus*

- * Se llamaba así al hombre libre que se entregaba a un empresario (*lanista*), el cual podía disponer de él como gladiador.

5) El *redemptus ab hostibus*.

- La persona que había caído prisionera del enemigo podía ser redimida mediante el pago de una suma de dinero. El *redemptus* quedaba luego obligado a tener que pagar con sus servicios el precio del rescate al *redemptor*. Según una constitución de Arcadio y Honorio se determinó que el plazo del reembolso no podía ser superior a 5 años, pasados los cuales quedaría saldada la obligación.

STATUS CIVITATIS

Significa la posición jurídica que ocupa un hombre libre dentro de la *civitas*. De acuerdo con ello, la clasificación sería la de distinguir: (A) los ciudadanos romanos; (B) los latinos y (C) los peregrinos.

Roma fue siempre muy celosa en lo referente a la concesión de prerrogativas o ventajas en la *civitas*. El criterio rector sería el de la *romanitas*, de acuerdo con el cual, cuanto mayor fuera el grado de romanización, es decir la adaptación al modo de ser romano, mejor sería la situación del individuo o del grupo en este *status civitatis*.

(A) LOS CIUDADANOS ROMANOS

Cómo se adquiere la ciudadanía. — Se es ciudadano romano ya sea 1) por nacimiento o 2) por un hecho posterior.

1) Por nacimiento era ciudadano romano aquel concebido por padres romanos unidos en *iustae nuptiae*. Fuera de esta unión había que considerar la situación de la madre, sin importar la del padre, por lo que era ciudadano el hijo de una madre romana en el momento del parto.

- A fines de la República se sancionó una *lex Minicia* según la cual el hijo habido de la unión de una ciudadana romana y un latino, o un extranjero, seguía la condición del padre, con lo que le rehusaba la ciudadanía romana. Esta ley fue derogada por un senadoconsulto de la época de Adriano.

2) Por hechos posteriores al nacimiento se podía ser ciu-

dadano romano: a) por la manumisión, por medios solémnes y cumplimiento de los requisitos de la *lex Aelia Sentia*, de un esclavo y b) por concesión especial expresa por el *populus* en los comicios —época republicana— o por senadoconsulto o una constitución imperial —época imperial—. Podía comprender a un solo individuo, o a un grupo, o un pueblo entero, y podía la concesión ser plena en cuanto a las prerrogativas o limitarse a algunas de ellas —*ius suffragii* o *ius connubii* o *ius commercii*.

Condición jurídica de los ciudadanos romanos. — I. La calidad de ciudadano romano representa la plenitud de prerrogativas de este *status (optimo iure)*. Tenían:

(A) *Ius publicum*

- *ius honorum*: posibilidad de poder acceder a las magistraturas (*honores*)
- *ius suffragii*: posibilidad de intervención y de voto en los *comitia*
- *ius sacrorum*: posibilidad de acceder a los *collegia* sacerdotales
- *ius provocationis* o *ad populum*: posibilidad de apelar en último grado al *populus* en los procesos criminales

(B) *Ius privatum*

- *ius commercii*: posibilidad de poder efectuar todos los actos y negocios jurídicos del *ius civile* —tanto para adquirir bienes, v. gr. *mancipatio*, como para obligarse, v. gr. *sponsio*
- *ius connubii*: posibilidad de poder celebrar *iustae nuptiae*. Consecuentemente, fundar una familia según el *ius civile*, con los efectos de la *patria potestas*, *agnatio*, etcétera
- *testamentifactio activa*: posibilidad de hacer testamento romano y
- *testamentifactio passiva*: posibilidad de poder recibir algo, como heredero o legatario, en un testamento romano
- *ius actionis*: posibilidad de poder recurrir al procedimiento romano mediante *actiones*

(C) *Munera* (cargas)

- *census*: obligación de anotarse en el censo
- *militia*: obligación de servir en las armas
- *tributum*: obligación hasta el 167 a.C. de pagar el impuesto

II. El carácter distintivo del ciudadano se denota en la prerrogativa de ser designado por los *tria nomina* (los tres nombres).

nombre individual - *praenomen*
 nombre gentilicio - *nomen*
 nombre familiar - *cognomen*
 a veces, un sobrenombre - *agnomen*

Marco Tulio Cicerón	Cayo Julio César	Publio Cornelio Escipión el Africano
---------------------------	------------------------	---

* En cuanto al liberto, llevaba su nombre particular precedido del de su antiguo *dominus*. Así, el esclavo *Stichus* manumitido por Marco Tulio Cicerón se denominaba *Marcos Tullius (Marci libertus) Stichus*.

Pérdida de la ciudadanía. — La ciudadanía romana se podía perder por: a) sufrir una *capitis deminutio maxima* que ocasionaba la pérdida de la *libertas* y arrastraba la pérdida de la calidad de *civis*; b) una condena política, por ejemplo la *interdictio aquae et ignis* (prohibición del agua y del fuego), con lo que se significaba simbólicamente que se lo ponía al margen de la *civitas*. Esta pena será reemplazada, en épocas de Tiberio, por la *deportatio*; c) abandonar *motu proprio* la ciudadanía romana y convertirse en ciudadano extranjero (*dicatio*).

(B) LOS LATINOS

Por debajo de la categoría de los ciudadanos romanos, pero en grado preferente a la de los extranjeros (*peregrini*), los romanos ubicaron a los latinos. Los había de tres clases.

1) **Latini veteres.** — Fueron los antiguos habitantes del *Latium*; luego se agregaron los miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina hasta su disolución en el 338 a.C.; también a otras comunidades no latinas se les concedió este *status*.

- * Se trataba de los ex aliados de Roma, sobre los cuales ésta había triunfado luego de una revuelta de la posteriormente disuelta Liga Latina. De acuerdo con la política romana, se los admitió por su similitud de costumbres y religión en una categoría muy cercana a la de los ciudadanos romanos.
- * Conservaban los *ura privata* — *connubium*, *commercium* — e incluso el *ius suffragii*, siempre y cuando estuvieran en Roma en oportunidad de las reuniones de los *comitia*. Carecían en cambio del *ius honorum*.
- * Sin embargo, tenían ciertas facilidades para asimilarse a los ciudadanos romanos: a) si se iban a vivir a Roma dejando un descendiente en su ciudad; b) si habían ocupado una magistratura en su país; c) si habían hecho condenar por concusión a un ciudadano romano.

2) **Latini coloniarii.** — Uno de los procedimientos arbitrados por los romanos para mantener el espíritu de la *romanitas* sobre las regiones que iban ocupando en Italia fue el de las colonias, que servían de centro de irradiación de ese espíritu. Unas colonias eran romanas y sus habitantes continuaban siendo ciudadanos; otras, eran latinas —formadas por latinos o por ciudadanos romanos que al irse de Roma perdían su categoría—. A estos últimos, a partir del 268 a.C., se los acostumbra llamar *latini coloniarii*.

- * Tenían el *suffragium* siempre que estuvieran en Roma en oportunidad de reunirse los *comitia*, pero no el *ius honorum*. Ejercían también el *commercium*, careciendo del *connubium*, a menos que les fuera concedido especialmente.
- * Este *status* les fue más tarde concedido a habitantes fuera de Italia con total prescindencia de su condición étnica, v. gr., Vespasiano se lo otorgó a todas las ciudades de España.
- * Si bien subsistieron después de la desaparición de los *latini veteres*, poco a poco fueron mermando, sobre todo por su naturalización. Con el *edicto de Caracalla* del 212 d.C., terminaron por extinguirse.

3) **Latini iuniani.** — Esta tercera clase de latinos corresponde a los libertos manumitidos de manera irregular, a los cuales, no obstante no ser étnicamente latinos, se los asimiló a este *status*.

(C) LOS PEREGRINOS

Los peregrinos o extranjeros eran aquellos pertenecientes a otras comunidades que mantenían relaciones con Roma, asegurándoles ésta ciertos derechos y garantías. Se oponían a los bárbaros, designación genérica de los pueblos que vivían fuera del Imperio.

- * Por un lado estaban los simples peregrinos a quienes Roma les había permitido el uso de sus leyes e instituciones locales (*cum civitate*): se regían subsidiariamente por el *ius gentium*.
- * Por el otro, estaban los integrantes de las ciudades dediticias, en general castigadas por su resistencia a Roma: se les prohibía tener instituciones propias (*sine civitate*). Se regían por el *ius gentium*, y no podían nunca ser ciudadanos.

STATUS FAMILIAE

Desde el punto de vista del *status familiae*, se dividen las personas en *sui iuris* y *alieni iuris*.

(A) SUI IURIS

Aquel que no está bajo la dependencia de otro. Tiene patrimonio, del que es responsable y puede obligarse por el mismo. Es el caso del *pater familias*.

- Un niño que quedaba huérfano de padre pasaba a la condición de *sui iuris* si es que no estaba sometido a la *patria potestas* de su abuelo o bisabuelo paterno. Lo mismo ocurría con la mujer cuando no estaba sometida ni a la *potestas* del *pater familias* ni a la *manus* del *pater* de la familia del marido.

(B) ALIENI IURIS

Son quienes no pueden actuar por sí mismos por cuanto están sometidos a la dependencia de otro.

- Son *alieni iuris* los sometidos a la *patria potestas* —los *fili familias*—, la mujer sometida a la *manus* y también los *fili familias* cedidos *in causa mancipii*.

Todo lo relativo al *status familiae* es tratado especialmente en el capítulo referente a la familia.

CAUSAS MODIFICATIVAS DEL "STATUS"

No obstante que una persona esté gozando de un determinado *status*, puede ver disminuido el ejercicio de sus prerrogativas por la existencia de ciertas causas modificativas de aquél.

(A) LA EDAD

Por razón de la edad podemos distinguir las siguientes condiciones:

- 1) Los infantes. Son los niños que no pueden expresarse jurídicamente. En la época de Justiniano, se determina que son los menores de siete años. No pueden celebrar por sí ningún acto o negocio jurídico.

2) Los impúberes. Son aquellos que no tienen el desarrollo físico para engendrar (*potestas generandi*). Respecto de la edad en la cual se entendía que alcanzaban la pubertad, se estableció que para las niñas ocurría a los 12 años; en cambio, respecto de los varones hubo una discusión entre las escuelas. Los proculyanos establecieron la edad de los 14 años; en cambio, para los sabinianos, había que determinarlo caso por caso mediante un examen realizado en el ámbito familiar (*inspectio habitudinis corporis*). Justiniano decidió la controversia inclinándose por la solución proculyana.

Los impúberes pueden ser clasificados como sigue.

a) Impuberes infantiae proximi. Eran aquellos que estaban asimilados aun a los infantes.

b) Impuberes pubertati proximi. Eran aquellos mayores de 10 años y medio, aproximadamente, y las niñas de más de 9 años y medio.

La importancia práctica de esta distinción radicaba en que para los *impuberes pubertati proximi* nacía la responsabilidad por actos ilícitos y la posibilidad de actuar con la *auctoritas* del tutor.

3) Los púberes eran de por sí capaces para toda clase de actos y negocios jurídicos, si bien al respecto se produjo una evolución.

a) Dada la inexperiencia que tenían estos jóvenes eran convencidos muchas veces de realizar negocios dañosos, incluso sin necesidad de que mediara dolo o error. Ante esa circunstancia se dictó la *lex Plaetoria* (año 192 a.C.), que estableció una serie de sanciones para todos aquellos que se aprovecharan negocialmente de los menores de 25 años (*minores*).

b) Si bien dicha ley parece ser que permitía el ejercicio de una excepción (*exceptio legis Plaetoriae*) para evitar que lo pudieran demandar con éxito al menor que hubiese celebrado un acto perjudicial, lo cierto es que el acto quedaba válido.

Por ello apareció el pretor concediendo a estos menores una defensa extraordinaria, la *in integrum restitutio*, que ocasio-

naba la nulidad del acto y la obligación de entregarse mutuamente las prestaciones intercambiadas con el tercero.

c) Pero esta medida favoreció tanto a los menores que en la práctica les representó un perjuicio, por cuanto nadie quería contratar con ellos por temor a la invalidez de los actos celebrados. Por ello fue que primero solicitaron del pretor un curador que los asistiera en cada negocio que pensaban hacer, ya que con la presencia del curador en el acto, no podían luego alegar la inexperiencia, base de la *in integrum restitutio*. Esta institución se fue haciendo tan normal, que por comodidad los propios *minores* eran los que iban a solicitar un curador permanente.

(B) EL SEXO

En principio, el papel de la mujer en Roma quedaba recluido al ámbito de la casa, aun cuando tenía una libertad de acción superior a la de otros pueblos, como, por ejemplo, el griego. Sin embargo, no participaba de la vida política.

Desde que nacía estaba siempre protegida por la sumisión a una *potestas*. Así, a la *patria potestas*. Si su *pater* no vivía, estaba bajo tutela,* la cual se transformaba en perpetua —al revés de la de los varones, que cesaba a los 14 años—. La única manera de escapar de esa tutela ejercida por sus agnados era contrayendo *iustae nuptiae* y sometiéndose a la *manus* de su marido.

* No podía ejercer la *patria potestas* de sus hijos; no podía actuar en juicio por otros; no podía contraer obligaciones en favor de terceros, dándosele una defensa en caso de que así lo hiciera. Recién en la época posclásica pudo, de acuerdo con el cumplimiento de ciertos requisitos, ser tutora de sus hijos.

(C) EL HONOR CIVIL. LA INFAMIA

La *infamia* era la forma de hacer perder a un ciudadano romano su honor civil de tal modo que se le modificaba gravemente su capacidad, puesto que se le impedía el acceso a las magistraturas, el poder votar en los comicios y también el poder actuar en juicio en lugar de otro.

En realidad, la institución no era simple, puesto que existía una *infamia censoria*, por la cual el censor como cuidador de las costumbres (*curator morum*) tachaba de infame al ciudadano indigno; una *infamia consularis*, por la cual el que presidía los comicios —por ejemplo, el cónsul— rechazaba la pretensión de elegibilidad de un candidato; y una *infamia praetoriana* que era la que le impedía actuar por otro en justicia.

Ya en la época de Justiniano, se establece una lista de *infames*: así, los que ejercen oficios deshonestos o deshonrosos como el ser artista de teatro o ser gladiador; los que ofenden a la moral, tales como el bigamo, la viuda que contrayera nupcias antes de cumplido el año de su disuelto matrimonio; el condenado por prevaricato y calumnia o el que violó la confianza depositada en contratos regidos por la *bona fides*, tales como comodato, depósito, sociedad, etcétera.

Juntamente con la *infamia (infamia iuris)* estaba la *turpitud (infamia facti)*, la cual era una desconsideración de hecho en virtud de la cual —sin llegar a ser infame— se los excluía de algunos actos: testimonio, tutela, etcétera.

(D) ENFERMEDAD MENTAL

Pueden darse dos casos: a) el *furiosus*, que es aquel que tiene alteradas las facultades mentales, y b) el *mente captus*, que es el insuficiente mental. La diferencia está dada en la posibilidad de intervalos lúcidos que tiene el primero —en los cuales los actos realizados son válidos— y que son imposibles para el segundo.

PERSONAS JURÍDICAS

La concepción de la persona jurídica es, en realidad, una construcción muy elaborada, realizada por la ciencia del siglo XIX. La idea radica en computar que determinadas organizaciones o sociedades alcanzan a tener una vida jurídica independiente de la de sus miembros, de tal modo que se configura una

persona capaz de tener su patrimonio, ser acreedora, deudora, concurrir a juicio, etcétera, a la que se califica de jurídica —término un tanto equívoco— para diferenciarla de las personas físicas.

En Roma, una idea tan elaborada no alcanzó a existir. No obstante ello, aparecen los primeros lineamientos de esta concepción, como puede apreciarse en las modalidades de las siguientes instituciones.

EL ESTADO ROMANO

Con el nombre de *populus romanus* se denomina el conjunto de todos los ciudadanos. Desde cierto punto de vista puede ser comprador, vendedor, arrendador, etcétera, pero ello no nos debe confundir en el sentido de ver allí a una persona jurídica en la concepción actual.

El estado se mueve para los romanos en el ámbito del derecho público (*ius publicum*), de tal modo que su patrimonio es un bien público, no pudiendo ser objeto de propiedad, ya que lo que es propiedad de todos no pertenece a nadie en particular. Además, los órganos con los cuales se maneja pertenecen siempre a la esfera pública, por lo que las relaciones y cuestiones surgidas entre un particular y el estado no son resueltas sino de una manera autoritaria por el propio estado, por cuanto los negocios que se hayan podido establecer no entran en el ámbito del *ius privatum*.

EL FISCO

A comienzos del Imperio apareció el *fiscus*, que no hay que confundir con el *aerarium* —tesoro del *populus*—, por cuanto se trataba de un patrimonio especial del César que se formaba fundamentalmente con lo aportado en carácter de tributos por los habitantes de las provincias asignadas a su cargo y del cual disponía con total independencia el *populus* y del Senado. A su muerte pasa al sucesor en el cargo de emperador.

No obstante su carácter reservado para la persona del sé

sar, ya que el fisco se halla en parte sometido al derecho privado, e incluso se puede hablar de deudores del fisco, estamos lejos todavía de poder ver en él a una persona jurídica en el sentido moderno, ya que por los privilegios de que goza, se encuentra por encima de las meras relaciones negociales privadas.

MUNICIPIOS

Los *municipia* o *civitates* tenían sus propios órganos de actuación. Acá nos encontramos con un germen más nítidamente trazado de personalidad jurídica, por cuanto el *municipium* participa de los actos jurídicos privados, pudiendo accionar y ser demandado judicialmente.

ASOCIACIONES

Es un vocablo genérico en el cual englobamos toda una serie de situaciones distintas, como, por ejemplo, la *sodalitas* —asociación de tipo religioso—, el *collegium* —por ejemplo, el de los pontifices—, la *universitas* y el *corpus*. Estas dos últimas son denominaciones más genéricas que engloban asociaciones de oficios, gremios, etcétera. En estos casos nos encontramos con la noción más cercana a la personalidad jurídica entendida en sentido moderno.

REQUISITOS Y FUNCIONAMIENTO

Los *collegia* y otras corporaciones existieron desde muy antiguo. Se encuentran permitidas siempre y cuando sus fines no sean *contra mores* (contrarios a las buenas costumbres), puesto que en ese caso el estado romano podía disolverlas.

Debido a cierta repercusión que tuvieron en la faz política estas asociaciones, donde a veces se encubrían otros propósitos, Augusto dictó una *lex Iulia* tendiente a reglamentar el funcionamiento de las mismas. Se estableció así que los requisitos para su existencia debían ser: 1) contar —en la reunión constitutiva— por lo menos con tres miembros; 2) tener un estatuto

(*lex collegii*) que reglara el funcionamiento interno y 3) que tuvieran un fin lícito.

Cada una de estas asociaciones alcanza a constituir una individualidad que se mueve jurídicamente con independencia de los miembros que la sostienen. Las principales reglas de su funcionamiento podrían resumirse como sigue:

- 1) Respecto de los bienes: la *universitas* tiene su propio patrimonio, el cual no se confunde con el de sus miembros.
- 2) Respecto de las obligaciones: la *universitas* puede ser acreedora por sí misma, y aquello que se obtenga es para ella y no para los miembros; lo mismo en caso de ser deudora, pues la que debe es ella y no sus miembros.
- 3) Respecto de la actuación judicial: la *universitas* es actora y demandada por sí misma; obviamente, alguien debe actuar por cuenta de ella, pero ese actor representa a la *universitas* y no a sus miembros, aun considerados globalmente.

FUNDACIONES

Las fundaciones representan en la doctrina actual una idea más avanzada que la de cualquier otra persona jurídica, ya que ésta aparecería —no obstante que se la configure como un ente distinto— respaldada por los miembros que la sostienen. En cambio, en la fundación, más que el soporte colegiado de personas, aparece un patrimonio afectado a la realización de un fin elevado. Constituida por el estado o un benefactor privado, si bien hay un grupo administrador, el que aparece como titular de derechos y obligaciones es ese patrimonio afectado que cumple su vida jurídica en sí mismo y realizando el fin propuesto. En Roma sólo se tuvo, luego de una lenta evolución, el primer sentido jurídico de estas fundaciones.

(A) Un romano podía en su testamento instituir a alguien como heredero cargándolo con un *modus**, el cual podía consistir en el cumplimiento de un fin altruista, como, por ejemplo, distribuir alimentos a los pobres o establecer un lugar como refugio para enfermos, etcétera.

En este caso se entendía que el heredero debía cumplir el *modus* impuesto, y si estaba asignado a ese fin piadoso (*pia causa*) un determinado capital, debía regentearlo como fiduciario que era de ese capital.

(B) Un paso más adelante se va a dar con la constitución de fundaciones de caridad, establecidas por los emperadores Nerva y Trajano, que consistían en otorgar a algunos municipios la administración de arrendamientos y préstamos garantizados, para que con el beneficio obtenido en calidad de alquileres o intereses se emplearan esas rentas en la manutención de gente humilde. Propietario de los capitales es el emperador y los municipios son sólo administradores.

(C) En la época de la Roma cristiana, la Iglesia tomará a su cargo la administración de muchos establecimientos de caridad y socorro para gente necesitada. Si bien la situación jurídica no resulta muy clara, cabe advertir que en algunos casos el patrimonio afectado funcionaba con una cierta independencia, dándose allí el germen de las fundaciones actuales. Así, con Justiniano, les estará permitido heredar, ser acreedoras, contraer obligaciones, etcétera.

CAPITULO VI

LAS COSAS

CONCEPTO DE COSA

En el sentido jurídico, cosa es todo ente o porción limitada del mundo externo al sujeto, al que el pensamiento social, por sus condiciones de utilidad, accesibilidad, apropiabilidad y relativa escasez, ha reglado las condiciones de aprovechamiento o enajenamiento para evitar o solucionar los eventuales conflictos de intereses entre los sujetos.

El vocablo latino *res*, de tan fluctuante significado como el español *cosa*, aparece usado en Derecho Romano, fundamentalmente, en dos sentidos.

I. El restricto coincide, aproximadamente, con la definición arriba dada de cosa en la materialidad o corporeidad.

• Este significado es el más frecuente: a veces se lo refuerza añadiéndole al sustantivo *res* el adjetivo *corporalis*; otras veces se lo reemplaza con *corpore* —cuerpos— o con *causa*, que es de donde procede nuestro vocablo *cosa*.

• De esas *res* toman su nombre, y sólo a ellas se refieren, los derechos reales, y con ellas se identifica la propiedad, resultando así, en el pensamiento romano, no escindible la cosa en sí del señorío sobre ella.

II. Otro, lato y de menor relevancia, en el que se comprenden no sólo las cosas corporales sino también otras incorpóreas que aparecen reducidas a los *iura*, o derechos, tanto los reales —con excepción de la propiedad, que, ya se ha visto, no se concebía con abstracción de la cosa que era su objeto— como los personales.

- Esta ampliación, puntualizada por Gayo, es una adaptación al campo jurídico de la división filosófica de las cosas en *corporalia* - *quae cerni el tangi possunt* (que pueden verse y tocarse) - e *incorporalia* - *quae intelliguntur* (que son concepciones del intelecto).
- Es probable que tal ampliación haya surgido de la necesidad de incluir en el concepto de patrimonio*, aparte de las cosas corporales - únicas que lo integraban en los primeros tiempos -, los derechos de crédito y los reales sobre cosa ajena.
- De todos modos, esa distinción no tuvo más trascendencia en la doctrina romana que un claro y práctico criterio de limitar a solamente las *res corporales* el ámbito de la posesión*, de la tradición* y de la usucapión*.

Así, pues, todo lo que de aquí en adelante se diga a propósito de la clasificación de las cosas se referirá a las corporales.

PATRIMONIO

La doctrina moderna considera patrimonio al complejo de derechos —reales y personales— y obligaciones de una persona, apreciable en el común denominador del dinero y constituyendo una universalidad jurídica distinta de los elementos que la componen.

Los romanos no llegaron a una tal abstracta y precisa noción.

- En la época arcaica, sólo las cosas corporales se consideraban en la órbita patrimonial del poder del *paterfamilias*.
- Luego se incluyeron los créditos, pero no las deudas, como se desprende del régimen de la adrogación* y de la *manus**. A esta etapa corresponde la definición que da Hermogeniano de *pecunia* —una de las palabras, junto con *bona*, usadas para referirse al patrimonio—: "Con el

nombre de *pecunia* se significan no sólo el dinero contante y sonante sino todas las cosas inmuebles y muebles y tanto las cosas corporales como los derechos*.

- Un paso más allá fue posible 1) a través de la idea, a propósito de la sucesión* *mortis causa*, de una necesaria relación entre la entrada en posesión de un conjunto de bienes y la obligación del culto privado y del pago de ciertas deudas del difunto, y 2) a causa de innovaciones del pretor al considerar el conjunto de bienes de una persona como prenda común de sus acreedores.
- Se llega así al criterio, más bien de carácter contable, del patrimonio como residuo de lo que resulta una vez deducidas las deudas.
- Por último, en algunos textos interpolados del "Digesto" se ha querido ver, no sin controversia, una concepción del patrimonio como una universalidad de derecho resultante de la suma de cosas, derechos y deudas.

De todos modos, el patrimonio llegó a quedar configurado en las concretas soluciones como una universalidad jurídica asignada como única al sujeto de derecho: a) el adquirente de un patrimonio en una *bonorum venditio* sustituye al antiguo titular en todas las relaciones jurídicas patrimoniales activas y pasivas, con alguna excepción; b) en ese supuesto la unidad del patrimonio impone de regla, con algunas excepciones, la confusión del patrimonio adquirido con el anterior, propio del adquirente; c) el patrimonio resulta tutelado por medios procesales y extraprocesales distintos a los que tutelan las cosas, derechos y situaciones de hecho que lo integran.

DIVISION DE LAS COSAS

Aparte de la distinción entre *res corporales* y *res incorpóreas* los juristas romanos establecieron otras que se referían a) a la condición jurídica fundamental, o sea a la aptitud o susceptibilidad absoluta o relativa de ser objeto de relaciones patrimoniales, o b) a diferenciaciones impuestas por concepciones o estructuras de la primitiva sociedad romana, o c) a características o particularidades que el pensamiento social subraya especialmente, de manera tal que dan lugar a tratamientos o regímenes jurídicos distintos.

DIVISION DE LAS COSAS SEGUN SU CONDICION JURIDICA FUNDAMENTAL

RES IN COMMERCIO - RES EXTRA COMMERCIIUM

I. Son *res in commercio* las susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos patrimoniales.

II. Por el contrario, la condición de *res extra commercium* aparece en las fuentes romanas: a) en sentido absoluto, como propia de las cosas a las que el ordenamiento jurídico considera —sea por su naturaleza física, sea por el destino que el pensamiento social le asigna— al margen de toda relación jurídica patrimonial; b) en sentido relativo, haciendo referencia a la imposibilidad de ciertas cosas de ser adquiridas por determinados sujetos o de, estando en el patrimonio de un determinado sujeto, ser alienadas.

RES IN PATRIMONIO - RES EXTRA PATRIMONIUM

La división entre *res in patrimonio* y *res extra patrimonium* tiene el mismo fundamento de la anterior, pero en las fuentes aparece también para caracterizar a las cosas según estén o no efectivamente en un patrimonio privado, con lo que quedan incluidas así en la categoría de *res extra patrimonium* aquellas que, siendo teóricamente susceptibles de ser objeto de relaciones patrimoniales, no lo son concretamente en un momento determinado, como es el caso de las cosas de una herencia yacente, de las *nullius* y de las *res derelictae*.

RES DIVINI IURIS - RES HUMANI IURIS

I. Las *res divini iuris*, caracterizadas por estar consagradas a los dioses, no pueden ser objeto de relaciones patrimoniales. Se dividen en *sacrae*, *religiosae* y *sanctae*.

(A) *Sacrae*. — Son las destinadas al culto de los dioses superiores —templos, altares, bosques sagrados— por medio de

una *consecratio* de los pontífices, concurrente con el consenso del *populus* —ley, plebiscito o senadoconsulto.

- En la época imperial es suficiente la sola *consecratio* efectuada por el emperador.
- A partir de Justiniano basta la *consecratio* efectuada por el obispo para dar carácter de *sacrae* a las cosas afectadas al culto cristiano, las que tienden, por lo demás, a confundirse con otros bienes patrimoniales de la Iglesia.

(B) *Religiosae*. — Son las cosas dedicadas a las divinidades inferiores, específicamente a los manes de los difuntos. Esencialmente el lugar —ubicado en *ager romanus privatus*, pero fuera de la ciudad de Roma— donde su propietario, responsable de los funerales, ha hecho enterrar un cadáver, aunque sea el de un esclavo, pero no el de un enemigo del pueblo romano.

- En lugar público o en suelo provincial, la inhumación de un cadáver no da carácter de *religiosa* a la sepultura.
- Si la inhumación ha sido efectuada sin orden o autorización del dueño del lugar, éste tiene medios procesales para obtener su precio o la remoción del cadáver, pero no puede efectuarla sin autorización.
- El sepulcro —inalienable por ser *res religiosa*— es, sin embargo, objeto de un derecho subjetivo, el *ius sepulchri*, no alienable pero transmisible a los herederos. Comprende la facultad de visitar y cuidar el sepulcro, atravesando, si fuese necesario, el circundante terreno perteneciente a un tercero.
- El *ius sepulchri* se confunde con el *ius inferendi*, derecho de ser enterrado o enterrar otros cadáveres en el sepulcro si quedase sitio. Este derecho si era patrimonial y alienable, y por lo tanto, no recaía exactamente en el sitio preciso ocupado por el cadáver que lo había convertido en *religiosus*.
- En el derecho de Justiniano el *ius sepulchri* se agota en el *ius inferendi*, de carácter patrimonial, consistente entonces en el derecho a lugares en los cementerios, pero sigue siendo extrapatrimonial el sepulcro.
- Al irse generalizando la costumbre de cementerios comunes a todos los fieles y considerados propiedad de la Iglesia, las *res religiosae* se fueron confundiendo con las *sacrae*.

(C) *Sanctae*. — Son las cosas puestas bajo la protección de los dioses mediante la ceremonia de la *sanctio*. Eran *sanctae* los muros y las puertas de Roma y de los municipios romanos y, probablemente, en época arcaica, los confines entre los fundos rústicos.

II. Las *res humani iuris*, individualizadas por la común característica de ser consideradas al servicio de los particulares

o de las comunidades, aparecen divididas por Gayo en privadas y públicas.

Las privadas son las que ya caracterizamos como *res in commercio* o *res in patrimonio*, en su valor absoluto.

Las públicas aparecen en las "Instituciones" de Justiniano subdivididas en (A) *res communes omnium*; (B) *res publicae* y (C) *res universitatis*, según se las considere que pertenecen a todo el género humano, al estado o a las *civitates*, concebidas como personas jurídicas.

(A) *Res communes omnium*. — Son las que, por el *ius naturale*, corresponden a todos los seres humanos en tanto tales. Son el aire, el mar, el litoral marítimo —hasta el límite de la mayor marea— y el agua corriente.

- Esta distinción, expuesta por Marciano, es criticable por su carácter filosófico pero poco jurídico. Considera algunas cosas —el aire, el mar— que, por su abundancia, disponibilidad y dificultad de apropiación exclusiva, no tienen las características de las cosas en sentido jurídico, y otras que en otros textos romanos aparecen como públicas —ríos, litoral marítimo— y aun como privadas —ciertas corrientes de agua.

(B) *Res publicae*. — Son aquellas sobre las cuales el *populus romanus* tiene no sólo soberanía sino propiedad.

Pueden distinguirse 1) aquellas "que, no en el patrimonio del *populus*, sino en el uso público son tenidas": los caminos y los ríos públicos, los edificios destinados a la función pública; 2) las que "están en el patrimonio del *populus*": los esclavos públicos, los bienes privados pasados al estado como botín de guerra o como resultado de condena o confiscación, etcétera.

- Las primeras son cosas *extra commercium* y en el período republicano eran administradas por los censores. Las segundas son cosas *in commercio* y fueron administradas por los cuestores.
- El goce individual de las cosas de uso público está protegido o con una *actio iniuriarum* —en tanto haya un ultraje o lesión a la personalidad— o con interdictos.

(C) *Res universitatis*. — Son las pertenecientes a las *civitates* del Imperio, en tanto personas jurídicas distintas del estado romano. Esos edificios y lugares se consideraron primeramente también como *res publicae* y su régimen siguió siendo el mismo.

DIVISION DE LAS COSAS PATRIMONIALES SEGUN CONCEPCIONES O ESTRUCTURAS DE LA PRIMITIVA SOCIEDAD ROMANA

RES MANCIPI - RES NEC MANCIPI

I. *Res mancipi* son las que en la Roma arcaica se consideraron objeto del *mancipium*: los fundos itálicos, ubicados en el *ager romanus* —extendido después del 90 a.C. a casi toda Italia—, las primitivas servidumbres rústicas sobre ellos, los esclavos y las bestias de carga y tracción —bueyes, caballos, mulas y asnos.

II. *Res nec mancipi* son todas las demás que se encuentran *in patrimonio*.

- Esta distinción tiene sobre todo relevancia a propósito de las transferencias de las *res*: las *mancipi* requerían formas solemnes como la *mancipatio* o la *in iure cessio* —ficción de proceso—. Las *res nec mancipi*, en cambio, se transmitían por simple tradición, es decir, entrega.
- Esta división, capital en el Derecho Romano, aunque entró en decadencia en el período clásico y desapareció bajo Justiniano, habría quedado estereotipada según concepciones y estructuras de la sociedad romana arcaica, de economía exclusivamente agraria y de autoabastecimiento de los grupos parentales.
- El origen de la división se atribuye, generalmente, a la mayor importancia de lo que en esa sociedad constituían los únicos bienes de producción.
- De todos modos, esa clasificación y la correlativa exigencia de la *mancipatio* para transmitir el *dominium* quiritarario —la variante más importante del poder del *paterfamilias* y, junto con la patria potestad, las únicas sobrevivientes hasta nuestros días— quedó cristalizada y subsistió por sentido conservatista, a pesar de que las condiciones de intercambio económico la hacían inconveniente.

COSAS MUEBLES - COSAS INMUEBLES

I. Cosas inmuebles, como su etimología lo indica, son las que no pueden ser movidas, trasladadas de un lugar a otro.

II. Cosas muebles son las movibles, las trasladables.

- En el derecho arcaico y clásico la distinción entre *res soli* (cosas del suelo), es decir el suelo y lo adherido por construcción, y las restantes cosas tenía relevancia para el régimen de la usucapción y de la tutela de la posesión.

- En el posclásico, la distinción adquiere fundamental relieve en cuanto a los negocios traslativos de la propiedad y viene así a sustituir la arcaica distinción entre *res mancipi* y *res mancipi*.

DIVISION DE LAS COSAS SEGUN DETERMINADAS CARACTERISTICAS O PARTICULARIDADES

COSAS CONSUMIBLES - COSAS NO CONSUMIBLES

I. Consumibles son las que perecen con el primer uso normal: alimentos, el dinero —que se pierde para su dueño cuando lo gasta—, combustibles, etcétera.

II. No consumibles son aquellas cuyo uso normal no implica su destrucción aunque produzca un cierto deterioro: una estatua, una casa, la vestimenta.

COSAS FUNGIBLES - COSAS NO FUNGIBLES

I. Fungibles son aquellas cosas que son consideradas en las relaciones patrimoniales no por su individualidad sino por pertenecer a un determinado género del cual importa solamente la cantidad —peso, número, medida—: los granos, el vino, el dinero, productos manufacturados en serie.

- También se llaman subrogables o representables porque son indiferentemente sustituibles por igual cantidad del mismo género.

II. No fungibles son las que tienen una individualidad propia tal que no pueden indiferentemente ser reemplazadas en su apreciación socioeconómica por otra cosa de un mismo género: una obra de arte, un esclavo, un fundo.

- Esta división adquiere especial relevancia en el campo de las obligaciones, en razón de la sustituibilidad y del principio de que "el género nunca perece".
- Todas las cosas consumibles son fungibles, pero no todas las fungibles son consumibles: los libros de una misma edición, productos industriales en serie, etcétera.

COSAS DIVISIBLES - COSAS INDIVISIBLES

I. Son divisibles las cosas cuando, fraccionadas, sus partes conservan la misma función económico-social que el todo: una

suma de dinero, una cantidad de vino, de cereal, etcétera.

II. Son indivisibles las que no pueden ser divididas sin que sufran cierto deterioro o mengua en su valor o función: una estatua, un edificio, un navío, un libro.

COSAS SIMPLES - COSAS COMPUESTAS - UNIVERSALIDADES DE COSAS

I. Son simples las cosas de las cuales los usos socioeconómicos no tienen en cuenta la inevitable pluralidad de los elementos constitutivos: un animal, una piedra, una viga.

II. Son compuestas las que, resultando de la unión o conexión de varias simples, adquieren, en razón de una distinta y específica función económico-social, una entidad jurídica inmutable aunque aquellas partes integrantes sean parcial o totalmente sustituidas: una casa, un barco, etcétera.

- Se admite una propiedad latente de una parte integrante distinta de la propiedad del todo y que la posesión o usucapión del todo no implique la de las partes integrantes.

III. Son universalidades de cosas los agrupamientos de cosas no conectadas materialmente y que conservan su individualidad, pero consideradas en su conjunto, y en razón de una propia función económico-social, como una unidad distinta y aislada del mundo externo y, consecuentemente, como un objeto unitario de relaciones jurídicas, que permanece idéntico e invariable aunque las cosas que lo componen disminuyan, aumenten o se renueven: un rebaño, una biblioteca, una colección de estampillas.

- No es romana la categoría de las universalidades de derecho o jurídicas, complejos patrimoniales que también tienen existencia autónoma de las cosas y derechos que lo integran: la dote, el peculio, la herencia.

PARTES DE COSAS - COSAS ACCESORIAS

I. Parte de una cosa es todo elemento —incorporado o no a la cosa— que, según los criterios y usos económico-sociales,

tiene función necesaria y perpetua en la constitución o perfección de la cosa: tejas, clavos y puertas con respecto a una casa.

II. Cosa accesoria es la que tiene una mera función instrumental con respecto a la cosa principal, es decir que es un medio para permitirle a ésta cumplir cabalmente su destino económico-social: los esclavos, animales y útiles de labranza con respecto a un fundo.

- Las partes de una cosa siguen la misma suerte jurídica que la cosa; pero no las accesorias, las que no se consideran involucradas en el negocio jurídico que tiene como objeto a la principal, a no ser que expresamente así se haya convenido.

FRUTOS

I. Frutos son las cosas que, producidas ordinaria y periódicamente por la cosa fructífera, no le alteran la esencia y constituyen entidades en sí mismas: la uva respecto del viñedo, la leña respecto del bosque, la lana y la leche respecto de la oveja; pero no los partos de las esclavas.

II. Además de estos frutos —llamados naturales—, jurídicamente se consideran también frutos civiles los rendimientos o réditos que se lucran periódicamente en virtud de un negocio jurídico que tiene como objeto una cosa: el alquiler producido por la locación de una casa, el canon pagado por la concesión de una explotación minera, el interés por el mutuo* de una suma de dinero.

III. Los frutos naturales tienen distinto régimen jurídico según sean: a) pendientes, los adheridos a la cosa fructífera y, por lo tanto, inexistentes como cosa en sí; b) separados, por cualquier causa, de la cosa fructífera, y, por lo tanto, con aptitud de ser objeto de relaciones jurídicas; c) percibidos los recolectados; d) no percibidos por negligencia del detentador de la cosa fructífera; e) existentes, todavía en poder del detentador de la cosa fructífera; f) consumidos, transformados o alienados por el detentador de la cosa fructífera.

CAPITULO VII

EL NEGOCIO JURIDICO

Los romanos acuñaron la expresión *negocio* (*negotium*, formada por la partícula negativa *nec* y la palabra *otium*), con el valor de significar aquellas operaciones de mercado con un fin utilitario o económico, por oposición al *otium*, interpretado en el sentido de dedicación a las tareas del espíritu. Sin embargo, debemos aquí aclarar que estuvieron muy alejados de construir una teoría del negocio jurídico. Dotados de una especial inclinación para resolver los problemas concretos que se presentaban en la instancia judicial, los jurisprudentes romanos centraron su atención sobre cada uno de los actos y negocios, aislándolos con una precisión ejemplar, para poder emitir su dictamen o parecer. Por ello es que de la mera lectura del "Digesto" lo que surge no es una teoría sino una casuística muy elaborada y precisa.

Pese a ello, del conjunto de todas esas soluciones quedaron establecidas las bases para la construcción de una teoría general. Esta fue la tarea a la cual se abocó la doctrina moderna, principalmente la pandectística alemana del siglo XIX, la cual, con una visión concorde con la de su tiempo, estructuró esto que se ha dado en llamar la teoría del negocio jurídico.

Hecha esta salvedad, trataremos metódicamente los principales problemas relacionados con este tema, lo que nos permitirá contemplar en forma genérica aquellos aspectos que los romanos trataron en forma específica en cada uno de los casos.

HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

Todo hecho es un acontecimiento que interesará al derecho siempre y cuando que por su intermedio se produzcan determinadas consecuencias jurídicas (nacimiento, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas). Cuando esos acontecimientos se producen naturalmente —sin intervención del querer humano— son llamados no voluntarios; cuando se producen queridos por el hombre son llamados voluntarios.

- Los hechos no voluntarios pueden ser meramente naturales, como por ejemplo, el transcurso del tiempo —que ocasiona jurídicamente el cumplimiento de los plazos—; la extinción natural de una cosa —como por ejemplo, el derramamiento de una vasija de aceite o la caída de un edificio—, que extingue por desaparición de la cosa el dominio que un sujeto tiene sobre ella —aun cuando en el segundo ejemplo el dominio continúa sobre el suelo y los escombros.
- Pero entran también en esta categoría aquellos acontecimientos en que interviene el hombre como mero ser natural, es decir, sin tener en cuenta su voluntad. Así, el nacimiento, que trae como consecuencia el comienzo de la persona y ocasiona determinadas relaciones en la familia; o la muerte, que elimina a una persona, hace cesar las relaciones familiares y determina eventualmente la apertura de su sucesión.
- Cuando, en cambio, interviene directamente la voluntad del hombre, estamos en presencia de hechos voluntarios. Así, el matrimonio, la aceptación de una herencia, la destrucción de una cosa por daño intencional y en forma culpable.

Los hechos voluntarios pueden a su vez tener como finalidad:

(A) la ejecución de un acto prohibido por el derecho y que éste sanciona de un modo determinado, en cuyo caso estamos en presencia de actos ilícitos.

- Los actos ilícitos determinan una categoría genérica que no se confunde necesariamente con la de delitos. En efecto, una cosa son los delitos, que están sancionados por el derecho con una pena —así el *furtum*, que en la época clásica está penado con el *quadruplum* del valor de la cosa robada si es *manifestum* o con el *duplum* si es *nec manifestum*—, pero

puede haber hechos ilícitos que no sean delitos; así, por ejemplo, un acto doloso que no es sancionado con una pena, sino con la anulación del acto o negocio, ya sea por medio de una acción —*actio doli mali*— o de una excepción —*exceptio doli mali*.

(B) procurar, por el contrario, una determinada consecuencia, dentro del marco del derecho, ya sea de nacimiento, modificación o extinción de una situación o relación subjetiva, y en tal caso estamos en presencia de actos lícitos.

Estos últimos son denominados, con más propiedad, actos jurídicos.

ACTOS Y NEGOCIOS JURIDICOS

Para algunos autores la expresión “negocio jurídico” resulta sinónima de “acto jurídico”, por lo que no corresponde ninguna diferenciación. En cambio, para otros se establece una distancia entre ambos conceptos. El criterio diferenciativo estaría dado por el mayor o menor poder de la voluntad en la eficacia concreta del caso específico. Así, tanto en el acto jurídico como en el negocio jurídico interviene la voluntad; pero mientras que en el primero actúa como un elemento cuyos presupuestos, modos y consecuencias están previamente establecidos por el derecho, en el segundo la voluntad juega más libremente, regulando las relaciones económico-personales de las partes.

- Demos un par de ejemplos. El pago sería un acto jurídico por cuanto el que lo efectúa manifiesta su voluntad, pero ocurre que el derecho previamente le ha fijado con precisión qué debe pagar, a quién debe pagar, cuándo debe pagar, cómo debe pagar, etcétera. Se ve aquí como el juego de la voluntad está totalmente constreñido por las reglas objetivas. En cambio, el testamento sería un negocio jurídico, ya que si bien quedan establecidas ciertas solemnidades obligatorias, no obstante el testador puede libremente instituir los herederos que quiera, desheredar a sus hijos, cargar a los herederos de legados, establecer modalidades, etcétera. Se ve pues, aquí, un juego más libre de la voluntad.
- Podríamos establecer en consecuencia que en el negocio jurídico existe a) una declaración de la voluntad b) dirigida a obtener un fin práctico, económico o personal, c) amparado por el derecho.
- Si bien en los ejemplos anteriores la diferenciación puede ser fácilmente apprehendida, mayor será la dificultad cuando tratemos de investigar la importancia de la voluntad en otros actos del Derecho Romano, como

por ejemplo los contratos, que habrá que analizarlos teniendo en cuenta la época y las particularidades de cada caso. Lo que sí tenemos que dejar anotado es que cuando la doctrina contemporánea habla de negocio jurídico está pensando en la llamada autonomía de la voluntad, concepto moderno y que, como tal, no existió en el Derecho Romano. De este modo, hay que tener especialmente en cuenta que la expresión *declarare voluntatem* no significará en el período clásico, ni aun en el posclásico, el concepto técnico que hoy día reconoce la doctrina como declaración de voluntad.

CLASIFICACIONES

Los actos y negocios jurídicos pueden ser susceptibles de diversas clasificaciones que nos ilustran acerca de su variedad.

(A) Unilaterales o bilaterales. — En los primeros, la existencia del acto o negocio dependerá de la voluntad de un solo sujeto: (el testamento, la manumisión, la aceptación de una herencia. En cambio, en los segundos, la creación estará supeditada a un acuerdo —*consensus*— de dos o más sujetos: el matrimonio, la *stipulatio*, la sociedad.

(B) Solemnes o no solemnes. — En los primeros, el derecho prescribe la observancia de formas muy precisas. Son tales, en general, los correspondientes al *ius civile*: así, la *mancipatio*, la *in iure cessio*, etcétera. En los segundos existe carencia de formas o libertad para establecerlos. Son tales, en general, los del *ius gentium* o *ius naturale*: así, la compraventa, el mutuo, la locación.

(C) Onerosos o gratuitos. — Los primeros suponen una ventaja económica que se adquiere por una contraprestación consistente en un desprendimiento patrimonial — así, la compraventa —; en los segundos, la adquisición de la ventaja se realiza sin contraprestación — como en la donación.

(D) Causales o abstractos. — En los primeros la existencia de la causa aparece ineludiblemente unida a la existencia del acto o negocio; por ejemplo, la compraventa, en la cual el fin tenido en vista es inseparable de aquella. En cambio, en los segundos, si bien puede existir una causa, ésta se oscurece en un segundo plano de significación, no dependiendo la existencia

del acto de su explicitación. Por ejemplo, en la *mancipatio* o la *stipulatio*, en las cuales lo que interesa es la realización de las solemnidades sin tener en cuenta el fin tenido en vista. La importancia de esta clasificación está en que si el acto o negocio es causal y la causa es ilícita, ello arrastrará la nulidad de los mismos; en cambio, si el acto o negocio es abstracto, la regla es que, en el mismo supuesto, producirá todos sus efectos, sin perjuicio de los remedios procesales que el pretor irá arbitrando a medida que transcurra la evolución del Derecho Romano.

(E) Inter vivos o mortis causa. — Los primeros son aquellos que tienen eficacia en vida de las partes: la locación, el depósito, etcétera. Los segundos, en cambio, regulan sus efectos para después de ocurrida la muerte del disponente: el testamento, el legado, etcétera.

ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO

Se distinguen tres clases de elementos en el negocio jurídico, los cuales, de manera implícita, se hallan en la legislación justinianea: esenciales, naturales y accidentales.

(A) ESENCIALES

Son aquellos sin los cuales no puede concebirse la existencia misma del negocio jurídico. Por ello son denominados también requisitos.

1) la manifestación de la voluntad.

- Al mencionar a la manifestación de la voluntad, damos por sobreentendida la existencia de un sujeto que a su vez cuenta con capacidad de derecho y de hecho para la realización de ese negocio. Por ello, algunos autores engloban a estos elementos con el nombre de presupuestos.
- La voluntad puede ser manifestada de manera expresa o tácita. Ocurre lo primero cuando se la formula verbalmente mediante palabras indubitables. Así en la *stipulatio*, cuando uno de los contratantes dice: "Prometo..." y el otro contesta: "Prometo". O también por escrito, como en el caso de los contratos literales. También se considera que es expresa la voluntad que se manifiesta por signos inequívocos; en una

compraventa, si alguien la propone y el otro la acepta por medio de una inclinación de la cabeza, o se señala el objeto del contrato designándolo con la mano.

- * La manifestación de la voluntad será tácita cuando, sin haber signos expresos de la actitud asumida por la parte, cabe reconocer con certidumbre la existencia de la voluntad. Así, si el que fue instituido heredero en una sucesión, sin haber dicho nada expreso, toma parte en el arreglo de los negocios de la sucesión (*pro herede gestio*), cabe entender que ha aceptado tácitamente la herencia. También el acreedor que recibe los intereses de un mutuo por un cierto tiempo, promete por esto mismo no reclamar el capital antes de que expire dicho término. Como se ve, en estos casos la interpretación de la actitud de la parte debe hacerse en correlación con el contexto de circunstancias que la rodean.
- * En cuanto al silencio, cabe decir que, en principio, no tiene valor. Así, si alguien me propone un contrato y yo nada digo, no se puede entender que lo haya aceptado. Sin embargo, este principio reconoce excepciones cuando por las circunstancias concretas la parte tiene obligación de expresarse y no lo hace. Así, si una *filia* manifiesta a su *pater* que contraerá nupcias y éste guarda silencio, no oponiéndose, cabe entender que las acepta. También, si una mujer casada que no vive con su marido anuncia a éste su embarazo, el silencio del marido es una confesión de su paternidad. Igualmente en la *in iure cessio*, ante la afirmación de una de las partes que vindica la cosa afirmando ante el magistrado ser suya, el silencio de la otra debe tomarse como conformidad con el acto.

2) el objeto.

- * Debe ser *lícito*, es decir ni contrario al derecho ni a las buenas costumbres. Así, (por ejemplo, no podría ser objeto de un negocio la sucesión de una persona viva). Este principio, que rigió durante la época clásica, se atemperó hacia el final, pues Justiniano lo permitió para el supuesto de alguien que realizara este tipo de negocio y hubiese perseverado hasta su muerte en el consentimiento dado. También sería ilícito el negocio que versara sobre la libertad de una persona; por ejemplo, si alguien pretendiese vender a un hombre libre como si fuera esclavo. Esto en la época imperial daría lugar a una sanción, y el que compró por error podía actuar para obtener una indemnización.
- * Debe ser *posible*, es decir, debe resultar factible. Así, (por ejemplo, no sería válido el negocio que versara sobre un objeto físicamente inexistente —un hipocentauro, un fauno, un esclavo después de su muerte— o jurídicamente imposible —un templo, por ser *res sacra* y en consecuencia ser *res extra commercium*—. Pero las cosas que pueden existir, aunque en este momento no existan, pueden ser objeto de negocios, entendiéndose en este caso que se trata de objetos futuros (así, la compraventa de la cosecha del año que viene).
- * Debe ser determinado —así, (por ejemplo, diez mil sestercios, el fundo tusciano, el esclavo Stichus—. Puede ocurrir también una cierta indeterminación, como en el caso en que el negocio versa sobre la entrega

de 500 medidas de trigo; aquí lo que constituye el objeto no es una especie, sino un género. En casos semejantes los negocios son válidos, pero no lo serían cuando la indeterminación llegare a ser suma; verbi-gracia si se establece el género, pero no se determina la cantidad —obligarnos a entregar trigo o aceite—. En realidad, si el negocio está suficientemente determinado, es una cuestión de hecho, y habrá que analizar cada caso en particular.

3) la causa.

- * La palabra causa —sumamente discutida en doctrina— fue empleada por los romanos en varios sentidos, por lo que corresponde analizarlos separadamente.
 - I. A veces es empleada en los textos en el sentido de causa-fuente —investigación del hecho, acto o negocio antecedente—. Así, por ejemplo, en relación con la *traditio*. Este acto supone la entrega material de una cosa por parte de una persona a otra. Pero para que funcione como operando la traslación de la propiedad, se torna necesario analizar el negocio-fuente en cumplimiento del cual se efectúa la *traditio*. Así, si era por una causa *emptio* (por causa de una compra), o una causa *donandi* (por causa de una donación), o una causa *dotis* (por causa de una dote), o una causa *solvendi* (por causa de un pago), se entendía que la *traditio* operaba la transmisión de la propiedad. En cambio, ello no ocurría si la causa-fuente era un comodato o un depósito, causas que no son hábiles para la transmisión de la propiedad. Se ve aquí, pues, claramente como la *iusta causa* (causa lícita) de la *traditio* debe referirse al negocio o acto antecedente. Igual significado existe para la *iusta causa* de la *usucapio*.
 - II. Otras veces, la palabra causa es empleada en el sentido de causa-fin, entendiéndose por tal el fin objetivo por el cual se realiza el negocio o acto. Si decimos fin objetivo, es para diferenciarlo nitidamente del fin o fines subjetivos, que serían más bien los "motivos". Pongamos un ejemplo: si yo celebro una compraventa, el fin objetivo, o causa-fin, será el convertirme —Juego de la *manipatio* o de la *traditio*— en dueño de la cosa; en cambio, los motivos pueden ser múltiples y en principio irrelevantes para el derecho: he comprado una casa porque me gusta, o porque queda cerca de mis amigos, o de mi lugar de trabajo.
- En el primitivo Derecho Romano, los negocios eran abstractos, es decir que no interesaba la explicitación de la causa. Así ocurría con el *nexum*, la *spensio*, la *stipulatio*. Por ello, si yo me obligaba por estos contratos, quedaba constreñido al cumplimiento de la prestación debida, aunque la causa fuere ilícita o contraria a las costumbres. En cambio, en el derecho posterior hubo que distinguir entre los negocios formales y no formales. En el caso de los primeros, se continúa el principio sentado anteriormente, pero el pretor irá, utilizando la aplicación de la *actio*, admitiendo ciertas defensas para el supuesto de una ausencia de causa o de ilicitud de la misma, como, por ejemplo, la *exceptio doli*. En los segundos, se exige una causa que sea real y lícita. En efecto, si no había causa, se admitía la *condictio sine causa*, la cual determinaba la

nulidad del negocio para el supuesto de que la causa por la cual se había hecho la prestación no había existido jamás —así, si yo le doy una cosa creyendo hacer un depósito y usted la recibe como si fuera una donación—, o no ha podido existir jurídicamente, como la nulidad de una dote entregada en virtud de un matrimonio imposible de realizar por la existencia de impedimentos.

4) la forma.

- Este elemento rige solamente para el caso de actos o negocios que sean solemnes. Cabe advertir que en el antiguo Derecho Romano, la regla general era la solemnidad de los actos. Se explica ello, en principio, porque los intérpretes del primitivo *ius* eran los pontífices, para quienes era muy familiar el uso de las formas rituales; de tal modo que fueron aplicando, por analogía con los viejos actos del *ius civile*, el uso de ritos verbales (*certa et sollemnia verba*), acompañados de gestos rituales, a veces con la mano, como en la *mancipatio*; a veces con una varita, como en la manumisión *per vindictam* o en la reivindicación. También se utilizaba el agregado de testigos —diez en la *confarreatio*; cinco en la *mancipatio*—, debiendo algunos celebrarse en presencia de un pontífice —como en el caso de la *adrogatio*, que debía suceder ante el *populus* reunido en los *comitia calata*—, o de un magistrado —como en la *in iure cessio*—. El cumplimiento ritual aseguraba igualmente una cierta publicidad y permitía el aseguramiento probatorio posterior.
- La tendencia posterior es ir liberando a los negocios de las formalidades solemnes. De este modo, vemos como la *mancipatio* será reemplazada por la vulgar *traditio*; los contratos verbales —*sponsio*, *stipulatio*— por los contratos consensuales, como la compraventa, o reales, como el mutuo.

(B) NATURALES

Son aquellos que no resultan necesarios para concebir el negocio jurídico, pero que están en la naturaleza del mismo. Por ello, aunque las partes no lo mencionen, lo mismo integran el negocio, estando implícitos en el mismo. No obstante esto, por no ser esenciales, las partes podrían determinar expresamente su exclusión.

- Ejemplos de elementos naturales son los vicios redhibitorios* y la garantía de evicción*. Digamos aquí que en un principio hubo necesidad de estipular expresamente el supuesto y la sanción respectiva de estos elementos. Así, el pago del *duplum* del valor de la cosa si se daba el caso de la evicción y la indemnización pertinente en caso de los vicios redhibitorios; pero luego, dada la *fides** en que se basan los negocios del *ius gentium*, se entendió que estos elementos estaban implícitos, salvo que expresamente se los excluyera.

(C) ACCIDENTALES

Son aquellos que se pueden lícitamente incorporar a un negocio jurídico, pero cuya existencia no se presume, sino que depende de la voluntad de la o las partes que los hayan o no querido incorporar. Generalmente se mencionan como elementos accidentales: 1) la condición, 2) el plazo y 3) el modo o cargo.

- Paulo incorporaba también la *accessio*, modalidad que se podía agregar a una obligación, ya por el sujeto (que el beneficio de la prestación sea para mí o para Ticio) o ya por el objeto (que me paguen a mí diez, o un caballo a Ticio). La lista podría ser más larga; así, se podrían agregar la "cláusula penal" (*stipulatio poenae*), la elección de un domicilio de pago para una obligación, y en general los distintos pactos que se pueden agregar a un contrato, como pacto comisorio, de *non petendo**, *in diem addictio**, etcétera.

1) CONDICION

Es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende la eficacia del negocio jurídico. Así, por ejemplo, si cuando realizo una *stipulatio* pregunto meramente: "¿Prometes darme cien?", el negocio es puro; pero en cambio, si establezco: "¿Prometes darme cien si viniera una nave del Asia?", el negocio depende de que se cumpla una condición.

- Es probable que la condición haya aparecido primeramente en los negocios *mortis causa*, pero luego se la pudo hacer figura en los *inter vivos*. Es curioso ver, tal como lo enseña Cayo, que sólo después de ciertas dudas se dilucidó la controversia en el sentido de admitir esta modalidad para la compraventa y la locación, y que recién en Justiniano la encontremos admitida para la sociedad.
- El acontecimiento debe ser futuro, ya que en el caso de ser pasado o presente, el negocio no queda sujeto a ningún elemento condicional. En efecto, sólo se pueden dar dos hipótesis: o dicho acontecimiento no es verdadero, es decir, no ha acontecido, con lo cual el negocio carece de validez; o por el contrario ha ocurrido, con lo que el negocio es válido en forma pura y simple desde el primer momento en que se celebró. Así, "te daré 100 si el rey de los partos viviese" puede contener un plazo —si es necesario un lapso para comprobar su existencia—, pero nunca una condición.
- Además, el acontecimiento debe ser objetivamente incierto, pues si fuera cierto, entonces sería un plazo.

* Cabe anotar también que determinados actos legítimos como la *mancipatio*, la *in iure cessio*, la *acceptilatio*, la *heredis actio*, la *actio tutoris*, etcétera, no son susceptibles de ser sometidos a condiciones.

Las condiciones pueden ser agrupadas en varias clasificaciones.

a) **Suspensivas o resolutorias.** — Se dice que una condición es suspensiva cuando la realización del acontecimiento futuro e incierto determina el nacimiento del negocio. En cambio, se dice que la condición es resolutoria cuando de suceder el acontecimiento se produce la extinción del negocio.

* Cuando los romanos hablan simplemente de condición, entienden siempre por tal a la suspensiva. Por ejemplo: “¿Prometes darme 100 si viniera una nave del Asia?”. En cambio, el supuesto de la llamada condición resolutoria fue encarado más bien como la existencia de un negocio puro al cual se suma un pacto resolutorio. Así, por ejemplo, una compraventa pura y simple a la cual se agrega el *pactum displicentiae*, en virtud del cual la venta es ahora *ad gustum*, de modo que el negocio se celebra, pero se lo da por resuelto si el comprador en un plazo determinado no aprueba la mercadería. O también si se le agrega el *pactum in diem addictio*, en virtud del cual la compraventa se tiene por no hecha si el vendedor, dentro de un tiempo determinado, recibe una oferta mejor. Vemos a través de estos ejemplos cómo el acaecimiento de esas circunstancias extinguiría el negocio. A partir de estos pactos se irá abriendo luego el camino para este tipo de modalidades resolutorias, pero digamos que las mismas van a ser miradas con desconfianza por los juristas romanos cuando se las relaciona con la libertad, por ejemplo, manumitir con condición resolutoria o con la propiedad y las situaciones del derecho hereditario, por cuanto estimaban contrario a las buenas costumbres sujetar a estadios dudosos situaciones como las mencionadas, que debían permanecer invariables.

* En la condición suspensiva debemos distinguir distintos momentos.

- 1) Mientras la condición no se ha cumplido (*pendente conditione*), el titular condicional no adquiere la efectividad de ninguna situación. Así, si se trata de un negocio obligacional, la prestación no resulta exigible, y tanto es así que si se pagase por error, se puede repetir lo pagado. Sin embargo, se va a ir afirmando la idea de que el titular goza de una expectativa, es decir de una esperanza, la cual se torna transmisible por vía hereditaria e incluso puede ofrecer ciertas exteriorizaciones. Así, el titular expectante puede lograr medidas conservatorias —por ejemplo, obtener garantía real— para el supuesto de que tema que se torne ilusoria su expectativa; del mismo modo, el deudor está obligado a respetar la situación creada, y si impide fraudulentamente el cumplimiento de la condición, la misma será reputada cumplida.
- 2) Si la condición se cumple (*condicio extitit*), el negocio adquiere plena eficacia como si fuera puro y simple. Así, la expectativa se transforma en exigibilidad si se trata de un negocio obligacional, o en consolidación

si se trata del dominio o de uno de los *iura in re aliena* *. Se plantean en doctrina el complicado problema de saber si en estos casos se opera la retroactividad de los efectos. Quienes se inclinan por la afirmativa sostienen que los efectos se operan *ex tunc* (desde que se celebró el acto); quienes se inclinan por la negativa, entienden que los efectos se operan *ex nunc* (desde ahora; es decir, desde el cumplimiento de la condición). La cuestión es muy controvertida, pero resulta más o menos claro que si existió la retroactividad de los efectos, no fue en la época clásica, sino en la justiniana. Serviría, por ejemplo, para explicar por qué si un *filius* celebró un negocio para su *pater* y cuando se cumple la condición es ya *sui iuris*, el negocio aprovecha no al *filius*, sino al *pater*.

- 3) Si la condición no se cumple o si se torna cierto que jamás se podrá cumplir (*defecta conditione*), ello ocasiona la extinción de la expectativa y todo transcurre como si el negocio no hubiese existido.

* En los supuestos de la llamada condición resolutoria, los efectos jurídicos comienzan a producirse a partir de la celebración del negocio, pero sobre éste pende la eventualidad de la resolución. Debemos, sin embargo, distinguir entre la condición meramente extintiva y la resolutoria. Así, en el primer caso —“Te presto mi casa hasta que venga mi tía del Asia”— el cumplimiento del acontecimiento hace cesar la permanencia del beneficio para el porvenir, pero no altera los efectos de la existencia pasada. En cambio, en la segunda —caso de la venta *ad gustum*—, el cumplimiento de la condición extingue la situación desvaneciéndose jurídicamente lo ya realizado. Es decir que, en ambos casos, la situación beneficiosa nace inmediatamente, pero la llegada del acontecimiento futuro e incierto amenaza de distinta manera.

b) **Positivas o negativas.** — En las primeras, la eficacia de un negocio se subordinará a la realización de un acontecimiento futuro e incierto —“Te daré 100 si hoy viniera una nave del Asia”—. En las segundas, la subordinación es a la no realización de ese acontecimiento —“Te daré 100 si hoy no viniera una nave del Asia”.

c) **Posibles o imposibles.** — La condición es imposible cuando el acontecimiento no se puede realizar a causa de un obstáculo que puede ser físico o jurídico. Así, es físicamente imposible establecer: “Te prometo 100 si tocas el cielo con las manos”. Es jurídicamente imposible establecer: “Te prometo 100 si vendes un templo a Ticio”, toda vez que por ser *res sacra* está fuera del *commercium*.

* Cuando se emplean estas condiciones en negocios *inter vivos*, éstos se consideran nulos. Sin embargo, los sabianos y juristas posteriores interpretaron, siguiendo el principio del *favor testamenti* (tendencia en

pro de la validez del testamento), que las disposiciones testamentarias sujetas a condiciones imposibles eran válidas, entendiéndose que se trataba de actos puros, considerándose como no puesta la condición.

- A su vez, si la condición imposible era formulada de manera negativa —por ejemplo, “Te daré 100 si no tocas el cielo con las manos”—, se consideraba que por ser de acaecimiento necesario, el negocio era válido.

d) **Lícitas o ilícitas.** — Se entiende que son ilícitas aquellas reprobadas por el derecho y las buenas costumbres. Así, “Te daré 100 si matas a Ticio”. La presencia de estas condiciones torna nulo al negocio.

- Los romanos establecieron una casuística interesante al respecto. Así, si se decía: “Te prometo 100 si no matas a Ticio”, esto también tornaba nulo el negocio, por cuanto no debe pagarse para permanecer honrado. Sin embargo, admitían el caso siguiente: una mujer que al casarse le plantease al marido: “¿Me prometes 100 si no abandonas tu costumbre de tener concubina?”, por cuanto aquí el beneficio no es para el que se debe abstener del hecho inmoral. También admitían esta otra: “Te daré 100 si impides que Ticio mate a Sempronio”, por cuanto se trataba de un hecho que podía sucederle a un tercero.

e) **Casuales, potestativas y mixtas.** — Se entiende que son casuales aquellas condiciones que dependen de un evento de la naturaleza o de la acción de un tercero. Así, “Te daré 100 si viniera una nave del Asia”.

La condición será potestativa cuando dependa del querer o de la actividad de la parte interesada: “Te daré 100 si fueras a Alejandría”.

La condición será mixta cuando dependa, en parte, de un evento natural o de un tercero, o de la actividad querida de la parte. Así: “Te daré 100 si te casas” —la voluntad de casarse estaría connotando lo potestativo, pero el hecho depende también del querer de un tercero, que es quien debe dar el consentimiento para contraer matrimonio con el beneficiario.

- Las condiciones puramente potestativas —“Te daré 100 si quiero”— se entienden carentes de seriedad y son nulas. Se plantea un problema con las condiciones potestativas negativas —“Te daré 100 si no subes al monte Capitolio”—, porque recién se podría comprobar el cumplimiento de la promesa cuando muriese la persona a la cual se refiere la condición. A inspiración del célebre jurista Q. Mucius Scaevola se admitió la *cautio Muciana*, según la cual el gravado podrá gozar del beneficio del negocio siempre y cuando preste caución de restituir lo adquirido para el caso de que hiciera aquello de

lo que debe abstenerse. Se la admitió en principio para los legados, pero en la época justiniana aparece también admitida para la institución de herederos.

2) PLAZO O TERMINO

Es el acontecimiento futuro y objetivamente cierto del cual se hace depender el nacimiento o la extinción del negocio jurídico.

- Lo que caracteriza al plazo es la certidumbre de que necesariamente el acontecimiento acaecerá, por lo que su función consiste en dilatar o retrasar el nacimiento —caso del plazo suspensivo— o la extinción —caso del plazo resolutorio— del negocio. En principio, las reglas que rigen para ambos son análogas a las analizadas para la condición.

Cabe, sin embargo, advertir que se puede admitir una cierta incertidumbre en el plazo. Los romanos analizaron los siguientes supuestos.

a) *Dies certus an certus quando* (se sabe con certeza que sucederá y se sabe cuando sucederá): “Te daré 100 para las calendas del mes de marzo”.

b) *Dies certus an incertus quando* (se sabe con certeza que ocurrirá, pero no se sabe cuando): “Te daré 100 el día de la muerte de Ticio”.

c) *Dies incertus an certus quando* (no se tiene certeza si ocurrirá; pero de ocurrir, se sabe cuando ocurrirá): “Te daré 100 cuando cumplas 20 años”.

d) *Dies incertus an incertus quando* (no se tiene certeza si ocurrirá y tampoco la hay sobre cuando ocurrirá): “Te daré 100 el día que se case Ticio”.

- Los dos últimos casos han sido vistos como disimulando condiciones disfrazadas, por lo que no serían estrictamente plazos. Creemos, sin embargo, que se puede dar una cierta tonalidad —muy pequeña, por ser éstos casos límites— de diferenciación. Así, por ejemplo, una cosa es decir: “Te daré 100 si viniera una nave del Asia” —acá el negocio queda supeditado en cuanto a su existencia misma a la realización de ese evento— y otra distinta, por ejemplo, es decir, a propósito de una compraventa: “Mira, ahora no tengo el dinero para pagarte el precio, pero te lo daré cuando venga mi amigo en la nave del Asia”. En este último caso lo que se quiere obtener es meramente un retraso o dilatación de una de las obligaciones del negocio, pero de tal modo que si el hecho no ocurre, el precio lo mismo quedará debido.

3) MODO O CARGO

El vocablo *modus* —de significación bastante vaga— sirve para designar una cláusula agregada a los actos de liberalidad —legados, donaciones, instituciones de herederos—, por medio de la cual se impone al destinatario del beneficio gratuito un comportamiento determinado. Un ejemplo sería éste, a propósito de una institución de heredero: "Que Ticio sea mi heredero. Pero que en el fundo que recibe levante un monumento funerario en mi memoria".

- * Sin embargo, no debe confundirse el modo con la condición —en este caso sería una condición potestativa: que sea mi heredero si me levanta un monumento funerario—. En efecto, en ésta la eficacia del negocio queda suspendida hasta tanto se realice el hecho; en cambio, en el modo la disposición de la institución de heredero es de efecto inmediato.
- * El problema que se presenta es saber cómo se puede exigir el cumplimiento del modo. En esto el Derecho Romano se movió muy cautamente, teniendo en cuenta las características de cada negocio. Debemos distinguir.
 - a) Cuando se trata de un legado *sub modo*, puede ocurrir que el legatario pretenda judicialmente obtener la cosa; en ese caso, a instancias del heredero, el pretor podía negársela hasta tanto no diera garantías suficientes (*cautiones*) que afianzaran el cumplimiento posterior del cargo. Luego, en el derecho imperial, para el supuesto de que el modo beneficiara a una persona concreta, se lo juzgaba como si fuera un fideicomiso*, de tal modo que el beneficiario gozaba de las medidas extraordinarias concedidas para el cumplimiento de este tipo de negocio.
 - b) Cuando se trataba de una institución de heredero*, podía ocurrir que fuera un solo y único heredero: en este caso, el testador podía haber establecido una sanción de desheredación si no cumplía el modo; igualmente, se admitió que cuando beneficiaba a una entidad religiosa (*collegium*) o, en general, a un interés público, el magistrado podía imponer una multa al heredero que no cumplía el cargo. A su vez, podía ocurrir que juntamente con el heredero instituido *sub modo* existieran otros herederos: en este caso, si no cumplía el modo, los demás —antes de la partición de la herencia— podían exigirle garantías (*cautiones*).
 - c) Finalmente, cuando se trataba de una donación*, el donante podía acompañar el traspaso del dominio —*mancipatio*— con un pacto de fidejucia*, por el cual el beneficiado se obligaba por su *fides* a cumplir la modalidad; si no lo hacía, el donante tenía una *actio fiduciae* para

asegurar el cumplimiento; igualmente lo podía hacer realizando una *stipulatio*. Luego, en el derecho posterior, se le admitieron al donante dos acciones: la *condictio causa data causa non secuta*, para recuperar la cosa donada, y la *actio prescriptis verbis*, si pretendía el cumplimiento del cargo o modo.

REPRESENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

El caso normal es que la manifestación de la voluntad sea efectuada por la propia persona a favor o a cargo de la cual se quieren producir los efectos del negocio jurídico. Pero existen casos en los cuales esa manifestación de la voluntad es realizada por una persona distinta. Estamos entonces en presencia de lo que genéricamente se puede denominar representación.

Acá debemos hacer una aclaración, por cuanto se pueden dar dos situaciones:

(A) Que el representante obre en nombre y a cuenta del representado, de tal modo que los efectos jurídicos resultantes se producen directamente en la persona del representado. Este caso se llama representación directa.

- * Ejemplos: A compra, en representación de B, un fundo a C. Las consecuencias de la adquisición serán directamente para B. Del mismo modo, A celebra con C un contrato de mutuo, en representación de B. B, de acuerdo con la hipótesis que nos planteemos, será directamente el acreedor o el deudor.

(B) Que el representante obre a cuenta del representado, pero a nombre propio, en el sentido de que los efectos del negocio jurídico se producen en la persona del representante. Este caso se llama representación indirecta.

- * Ejemplos: A compra, a cuenta de B, un fundo de C. La adquisición del objeto será para A, quien deberá luego transmitirla a B, quien tendrá las acciones pertinentes para exigirlo. Del mismo modo, A celebra con C un contrato de mutuo, a cuenta de B. Quien queda como acreedor o deudor es A, que —de acuerdo con la relación interna existente entre representante y representado— deberá entregar el objeto del contrato a B, teniendo acción para demandarle el monto de la devolución del pago.

La representación directa, que es en realidad lo que la doctrina moderna llama propiamente "representación", es relativamente reciente, demandando una muy desarrollada capacidad de abstracción. Los romanos, en cambio, utilizaron la noción de representación indirecta.

* Esta circunstancia se podría explicar porque a) en el comienzo los actos jurídicos en Roma son formales, exigiéndose la intervención personal y directa del sujeto jurídico; y b) por la constitución de la misma familia romana, en la que el eje de los negocios está centrado en el *paterfamilias*, y éste no necesita recurrir a personas extrañas, ya que cuenta con los miembros de su propia familia, que están sujetos a *potestas* (*filiifamiliae* y esclavos), y los utiliza para la celebración de los negocios.

* Analizaremos los principales casos que se presentaban.

a) Está en primer lugar la figura del *nuntius*. Este es tan sólo un vehículo de la voluntad del *pater*, prestando únicamente una colaboración subordinada; es decir, algo así como "un brazo prolongado" o un "instrumento animado" que se limita a transmitir la declaración ajena. Por ello, técnicamente no es un representante. Podía actuar solamente en aquellos actos ausentes de formas, como en los contratos consensuales, en la adquisición del dominio por mera aprehensión de la cosa —*occupatio*—, o en el repudio de la mujer en el caso del divorcio. En cambio, no puede celebrar actos solemnes —*mancipatio*, *in iure cessio*, etcétera.

Entran en esta circunstancia los *filiifamilias*, a quienes se equipara la mujer sometida a la *manus* y los esclavos. Aquello que adquieren, aun sin noticia del *pater*, ingresa al patrimonio de éste. En cambio no lo pueden, en principio, obligar, salvo en los supuestos que por atención a la *aequitas* irá admitiendo el pretor con las figuras de las *actiones adiecticiae qualitatis*.

b) Las figuras más comunes, en el derecho clásico, de representantes por cuenta de otro serán las del mandato, contrato en el cual el mandatario se obliga a llevar a cabo un negocio por cuenta del mandante y la gestión de negocios, en virtud de la cual una persona, el gestor, lleva a cabo negocios en provecho de otro, sin habérselo encargado éste.

c) Otro caso especial está dado por las figuras del tutor y del curador. Estos ejecutarán ciertos actos en sustitución del incapaz (por ejemplo, del pupilo impúber o del *furiosus*). En el fondo, se explica ello por una *fiducia*; es decir, una relación de "confianza" basada en la *fides*. Tanto el tutor, como el curador cumplían una "carga pública" a los efectos de proteger a los incapaces. Por eso algunos autores hablan de una representación legal o necesaria.

El modo de actuar es el que corresponde a la representación indirecta: adquirirían para sí mismos, transmitiendo luego lo adquirido a sus representados. Lo mismo sucedía con las obligaciones, si bien tenían también acciones útiles contra el que hubiera estado sujeto a tutela o curatela por los negocios celebrados en el interés de éste.

Pese a esta regla general, se admitió que tanto el tutor como el curador podían disponer, como si fueran dueños, del patrimonio del pupilo o del sujeto a curatela para determinados actos, de los cuales debían dar luego rendición de cuentas. Ya en la época clásica se les admite adquirir para el pupilo la posesión y el dominio.

d) No obstante que seguía funcionando la regla de que "por personas extrañas no podemos adquirir", hay que dejar anotada la figura del *procurator*, es decir, de una persona extraña que se ocupaba de los negocios de otra —*factotum*—. Significó esto una lenta evolución hacia determinados casos en los que se podría hablar de "representación directa". Así, según un párrafo de Neracio, se permite por medio del *procurator* adquirir la posesión. El problema en torno de si se podía adquirir el dominio estaba en cambio muy controvertido —salvo para el caso de adquisición por *usucapio* o por *praescriptio longi temporis*—. Según otros textos, se la permitió para adquirir la *bonorum possessio* y el *constitutum*.

INTERPRETACIÓN DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

I. Los negocios jurídicos deben ser interpretados para tratar de desentrañar su contenido y el alcance que los mismos tienen. Este problema fue encarado de manera sistemática por la doctrina moderna, principalmente por la pandectística alemana del siglo XIX, la cual elaboró con enjundia los principios doctrinarios.

Fundamentalmente, se han destacado los dos aspectos que tiene la "manifestación de la voluntad", que están señalados por la voluntad como hecho interno —tendiente a responder a la pregunta ¿qué es lo que realmente quiso decir el que celebró el acto?— y la voluntad como hecho manifiesto y externo —tendiente a responder a la pregunta ¿qué es lo que realmente dijo el que celebró el acto?—